

信賴保護原則的捨繁取簡^{*} —— 理論基礎的反省與要件重構

林起衛^{**}

摘 要

本文認為，信賴保護原則的理論基礎，不在誠信原則或法安定性原則，而係「憲法基本權保障」。正因如此，使得信賴保護原則具有憲法位階，得以拘束國家公權力行使，包含立法及行政兩權皆是。承此，信賴保護原則的課題內涵旨在保護人民的「主觀公權利」而非主觀信賴，並且針對此該權利之保護，探究國家得否對法秩序為不利人民之變更，並強調國家此侵益措施如對人民權利造成過度侵犯，必須採行補救措施或過渡期間條款以資緩和。如果上述前提得以確立，則信賴保護原則的要件設定，毋須求諸於「信賴基礎」、「信賴表現」與「信賴值得保護」等階層體系，回歸基本權（自由權）受干預之審查架構，即為已足。

關鍵詞：誠實信用原則、法安定性原則、憲法基本權保障、法律不溯及既往原則、行政損失補償請求權、過渡條款、特別犧牲、基本權核心理論、人性尊嚴、死刑。

* 投稿日：2013年4月2日，接受刊登日：2013年9月27日。〔責任校對：張文愷、郭昇伶〕。

感謝兩位匿名審稿委員及本刊出版委員會之寶貴意見，謹此敬表謝忱。

** 東吳大學法學院法律學系碩士。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/51106151.pdf>。



目 次

- 壹、前言
- 貳、信賴保護原則理論基礎的尋繹
 - 一、誠實信用原則
 - 二、法安定性原則
 - 三、憲法基本權保障
- 參、通說信賴保護原則要件審查模式之檢討
 - 一、信賴基礎
 - 二、信賴表現
 - 三、信賴值得保護
 - (一)以不正之方法而獲取處分者
 - (二)對重要事項提供不正確資訊或為不完全陳述而獲取處分者
 - (三)明知或因重大過失不知處分違法者
 - 四、小結
- 肆、信賴保護原則的要件重構
 - 一、公權利的存在
 - (一)概論
 - (二)具體之行政行為
 - (三)抽象之法規範
 - 二、公權利受侵害
 - (一)具體行政行為之作成
 - (二)不利新法之訂定(含授益法規的廢棄變更)
 - 三、法律保留原則
 - 四、比例原則
 - (一)概論
 - (二)具體侵益措施的採行
 - (三)抽象法規的不利變更
 - 五、損失填補
 - (一)概論
 - (二)具體侵益措施的損失填補
 - (三)不利新法的損失填補
 - 六、小結
- 伍、相關釋字簡評
 - 一、司法院釋字第410號解釋
 - 二、司法院釋字第525號解釋
 - 三、司法院釋字第529號解釋
 - 四、司法院釋字第574號解釋
 - 五、司法院釋字第577號解釋
- 陸、立法建議
 - 一、刪除知悉處分違法即排除保護之規定
 - 二、刪除行政機關撤銷授益處分之期限規定
 - 三、增訂行政機關之對內求償權
- 柒、結語

壹、前言

濫觴於德國法制的「信賴保護原則」(der Grundsatz des Vertrauensschutzes)，隨著國內學者的大量引進與長年對話，其初步架構已漸成形，不過信賴保護原則看似容易，其間卻存在諸多爭議，其主要原因，在於信賴保護原則之「理論基礎」究竟植基於何處，學界仍未取得明確之共識。法安定性原則雖係德國學說實務之主流見解¹，惟另有認為應以憲法基本權保障較為可採²，而我國釋憲實務則以誠信原則、法安定性原則、憲法基本權保障三者組合的方式共構之（司法院釋字第525號解釋理由書、第589號解釋、第629號解釋理由書參照）。

-
- 1 BVerfGE 13, 261 (271); 45, 142 (167 f.); 59, 128 (164); 72, 175 (196); 105, 48 (57); Klaus Vogel, Rechtssicherheit und Rückwirkung zwischen Vernunftrecht und Verfassungsrecht, JZ 1988, S. 833 (834); Fritz Ossenbühl, Vertrauensschutz im sozialen Rechtsstaat, DÖV 1972, S. 25 (27); Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl., 2009, § 11 Rn. 22; Hubert Meyer, Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes, in: Knack (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar, 8. Aufl., 2004, § 48 Rn. 91; Andreas von Arnould, Rechtssicherheit, 2006, S. 150 ff.; 陳新民，法治國家理念的靈魂——論法律溯及既往的概念、界限與過渡條款的問題，收於：法治國家論，頁 173（2001 年）；李建良，法律的溯及既往與信賴保護原則，台灣本土法學雜誌，24 期，頁 84（2001 年）；陳敏，行政法總論，8 版，頁 90（2013 年）；林錫堯，行政法要義，3 版，頁 59（2006 年）；陳愛娥，信賴保護原則的具體化——兼評司法院大法官相關解釋，台灣本土法學雜誌，98 期，頁 186（2007 年）；蔡宗珍，退休公教人員優惠存款措施之法律關係及相關信賴保護爭議析論，臺大法學論叢，40 卷 1 期，頁 124（2011 年）；林昱梅，論溯及性法規之合法性問題——從土石採取法「環境維護費收費基準」之時間效力談起，東吳法律學報，23 卷 4 期，頁 10 以下（2012 年）。
- 2 BVerfGE 13, 275 (293); 45, 142 (168); 53, 257 (309); 95, 64 (86); 105, 17 (37 f.); Eberhard Grabitz, Vertrauensschutz als Freiheitsschutz, DVBl. 1973, S. 675 (681 f.); Walter Schmidt, „Vertrauensschutz“ im öffentlichen Recht: Randpositionen des Eigentums im spätbürgerlichen Rechtsstaat, JuS 1973, S. 529 (532 ff.); Johannes Möller/Alfred Rühmair, Die Bedeutung der Grundrechte für die verfassungsrechtlichen Anforderungen an rückwirkende Gesetze, NJW 1999, S. 908 (910); 陳愛娥，國小校長的「遵用」或「遴選」——法律溯及既往原則的相關問題，台灣本土法學雜誌，21 期，頁 142（2001 年）。

在理論基礎之立足點已出現分歧，影響所及者，係隨之而來的要件審查架構問題——亦即信賴保護成立三要件審查體系（信賴基礎／信賴表現／信賴值得保護）之設定是否合宜妥當；為何於抽象法秩序之變動不能適用此要件審查體系，而須另創設出法律不溯及既往之論述模型；又如認為信賴保護原則應優先以憲法基本權加以實現³，則公法學既有之憲法基本權（自由權）受干預審查架構，其與前述兩種體系模型間，係處於優先次序、同時併行或任意選擇關係？或者應更深入的提問：在憲法基本權保障之餘，另保護人民之信賴利益，究為法治國所應遵循之憲法誠命，抑或只是疊床架屋的制度設計？上述諸多問題，都必須回到信賴保護原則的起點——理論基礎的定位，方能為學說爭議的解決找到方向指引，進而形塑出體系制度間應有的均衡與理性。

信賴保護原則雖旨在處理法秩序之不利變更，惟有別於多數見解關注於人民對舊法秩序所生之信賴，本文認為應著重此高權侵益措施（新法秩序）之得否作成，屬於憲法基本權（自由權）之防禦面向；因此除了應導入法律保留原則、比例原則之規範控制外，尚有進一步審酌「有無採行補救措施或訂定過渡期間條款」之必要，方能達成節制國家公權力行使，以成就人民權利保護之憲法意旨。是以，為求上述論點之證立，本文在以下的段落安排，係先以尋繹出信賴保護原則的理論基礎究竟何在（以下貳、），次而依此檢討現今多數見解採行之三要件審查體系（信賴基礎／信賴表現／信賴值得保護）（以下參、），後則嘗試提出個人見解代替之（以下肆、），並運用於我國信賴保護原則之代表性釋字以為檢驗（以下伍、），文末則提出立法建議（以下陸、）與個人感想（以下柒、）作為總結。期待在此思辨過程中，能為存在已久的學說爭議帶來釐清，進而正確把握人民與國家間之關係分際。

3 Bodo Pieroth, Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundsatz des Vertrauensschutzes, JZ 1990, S. 279 (283).

貳、信賴保護原則理論基礎的尋繹

我國司法院釋字第525號解釋理由書提及：「法治國原則首重人民權利之維護、法秩序之安定及誠實信用原則之遵守。人民對公權力行使結果所生之合理信賴，法律自應予以適當保障，此乃信賴保護之法理基礎……」（司法院釋字第589號、第629號解釋理由書亦同）。其認為「誠實信用原則」、「法安定性原則」與「基本權之保障」三者共同構成信賴保護原則之理論支柱⁴。循此，本文以下分別檢視上開各原則之內涵及其與信賴保護原則之關係，以之作為信賴保護原則之根本基礎與體系內涵之開展。

一、誠實信用原則

「誠實信用原則」（Grundsatz von Treu und Glauben）之概念，本身帶有公平、正義等倫理色彩，其進入法律關係作調控，乃具有補充現行法之不備，或緩和實定法過於僵化之弊，以求得個案處理時之具體妥當性（Billigkeit）⁵。誠實信用原則之出現係源於債法，旨在保護當事人間之契約利益，後演變成為私法主體間權利義務行使之基本原則（我國民法第148條第2項）。至於公法領域是否有誠實信用原則之適用，在經過學說、實務漫長的探究下，逐漸由類推適用走向直接適用，甚至將誠實信用原則提升至「一般法律原則」層次，使之得以拘束所有國家行政行為之行使。而誠實信用原則對於信賴保護原則之意義，在於要求國家須謹守誠信，其行為應前後一貫，不能舉措反覆而失信於民⁶。我國行政程序法第8條規定：「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之

4 不同於此，有學者指出信賴保護原則之理論基礎究竟何在，是十分不明確的。請見 Günter Püttner, Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, VVDStRL 32 (1974), S. 200 (201 ff.); Hartmut Maurer, Staatsrecht I, 5. Aufl., 2007, § 17 Rn. 114 f.

5 洪家殷，信賴保護及誠信原則，收於：臺灣行政法學會編，行政法爭議問題研究（上），頁132（2000年）；陳敏（註1），頁88-89。

6 採此見解：BVerwG, NJW 1960, 692 (693); Ossenbühl (Fn. 1), S. 27.

信賴。」其將誠實信用原則與信賴保護原則兩者並列，其意在此。

從國家權力之來源以觀，民主國家為汲取民意所奉行之國會定期改選（司法院釋字第499號解釋）與屆期不連續原則（立法院職權行使法第13條），即已反映出國家決策在本質上係不斷演替與更新之事實。因之國家對既存法秩序的調整，不能以「國家不正行為」視之。倘基於既得利益之維護與人民期待之信守，而不許國家為法秩序之形塑或更新，不啻使國家因應時勢變遷與公益形成之功能盡失，而須受限於既有之立法者意志，馴至國家庶政動彈不得而無所作為，自有未當⁷。

復以，誠實信用原則之適用，旨在求得具體法律關係下之個案正義，惟信賴保護原則所涉及之案例類型，除具體之行政行為外，尚包含抽象法規範之修正變遷⁸，則誠實信用原則得否由具體個案之適用，躍升為指導法律制定之「立法原則」，實有待商榷。申言之，誠實信用原則雖作為行政法上一般法律原則，惟該法律原則是否具有「憲法位階」，而得以拘束所有國家公權力之行使，誠可置疑；特別在受益處分撤銷之際，其須與具憲法位階之「公益原則」兩相取捨⁹，倘作為信賴保護原則理論基礎之誠實信用原則不具備憲法位階，則在公益與私益的權衡下，勢將得出違法處分應「一律撤銷」之結論，而無採取存續保護之可能。

二、法安定性原則

「法安定性原則」（*der Grundsatz der Rechtssicherheit*）強調國家對既已存在之法秩序，應確保其本身之持續與平和，人民始能對之

7 *Vögel* (Fn. 1), S. 835; *Gunter Kisker*, Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, VVDStRL 32 (1974), S. 149 (178); 陳愛娥（註1），頁160；蔡宗珍（註1），頁124。

8 林合民，公法上之信賴保護原則，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁31（1985年）。

9 李建良，從公法學之觀點論公益之概念與原則，國立中興大學法律研究所碩士論文，頁80-90（1986年）。

產生可預見性與可預測性，並在此基礎上投以信賴而開展個人生活之安排。因而德國聯邦憲法法院一再地指出：「對人民而言，法安定性首意謂著信賴保護」¹⁰。

參酌法安定性原則之概念形成，其本身存在之盲點是：何以法秩序的現行有效，即可導出人民有能力預見——該法秩序將於日後依舊保持持續安定，並得對之投以信賴。蓋於民主國原則下，國家有不斷因應時勢變遷與形成公益之任務需求，從而法秩序在本質上就不可能是安定平和的。因此，人民應不能信賴國家政策將保持存續、或預見法律將永久實施（司法院釋字第525、620號解釋參照），否則在公法學的評價上，此等主觀心態顯然是「錯誤的期待」，自應不予保護。

此外，鑑於法治國中「權利」之有無，首應探求立法者之規範意旨（司法院釋字第469號解釋參照），惟法安定性之設定，卻完全跳脫法規意旨之探尋，僅憑人民對既存法秩序投以信賴，即可要求國家對之保護；換言之，客觀法秩序都不必然導出主觀公權利，卻可導出應受保護之信賴，信賴保護原則之成立顯然過寬。其次，法安定性下之信賴利益並無「社會義務」之概念，亦即其不過問有無構成「過度侵犯」（特別犧牲）之問題，而是只要法秩序變動衝擊到人民之信賴，國家即負有採行補救措施或訂定過渡條款之義務；相較於公權利，對人民之信賴保護顯有過之而無不及。而成立方式過於寬鬆、保護方式更為優厚，如此之推導，往往使信賴保護原則的美意，淪為既得利益者之護身符、阻礙國家改革進步的絆腳石。

實則，法治國之所以限制立法者為不利新法的訂定，並非考量人民對法秩序的信賴，而是在於其構成人民自由權利之侵害（憲法第23條）。更重要者係，法秩序本身有無持續、穩定應非目的，毋

¹⁰ 詳見註1所列之參考文獻。

寧人民之權利保護方為首要¹¹。正因為如此，學說普遍認為於「負擔」處分的撤銷廢止中，因該廢棄行為對人民有利，從而原則無信賴保護之問題¹²；同理，在抽象法規範的變動上，原則上有利人民可以溯及，不利則否¹³。於此皆反映出：法秩序安定與否僅為其次，唯有人民權利之保護，才是應盡可能實現的最佳化命令（Optimierungsgebote）。

三、憲法基本權保障

近代立憲主義下之憲法，旨在節制、對抗國家權力之行使，以成就人民權利之保障。信賴保護原則在此憲法框架下的理解，並非指向國家舉措應合乎誠信，或者是法秩序將持續安定，毋寧是人民可以預見：即便日後國家出於公益考量而有變動現行法秩序之需求，他的既得權益，也不會在此變遷的過程中遭到漠視、犧牲；甚至為了避免使他遭受到難以回復之重大損失，國家可能須放棄變動法秩序措施之採行（存續保障）。而支持他得以預見之基礎，便是「憲法基本權保障」。

憲法基本權保障之理念設立，其旨在對抗處於高權優勢地位之國家，用以確保人民自由與權利之完整。而由「基本權的針對國家性」以觀，國家不能享有基本權，自不能主張憲法基本權保障¹⁴；

11 司法院釋字第 574 號許玉秀大法官部分協同意見書、釋字第 605 號許玉秀大法官協同意見書。

12 Maurer (Fn. 4), § 8 Rn. 50; Wolf-Rüdiger Schenke, Probleme der Bestandskraft von Verwaltungsakten, DÖV 1983, S. 320 (328); 林三欽，論授益行政處分之撤銷——思考層次與考量因素的探索，收於：「行政爭訟制度」與「信賴保護原則」之課題，頁 364（2008 年）。

13 Hans D. Jarass/Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Kommentar, 10. Aufl., 2009, Art. 20 Rn. 67; Maurer (Fn. 4), § 17 Rn. 117; Ossenbühl (Fn. 1), S. 32.

14 Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Staatsrecht II: Grundrechte, 24. Aufl., 2008, S. 40; 許宗力，基本權利對國庫行為之限制，收於：法與國家權力（一），頁 43（2006 年）。

從而以憲法基本權保障推導而出之信賴保護中，理應不許國家成為受保護之對象，而宜排除「國家對人民」或「國家機關相互間」主張信賴保護之可能。

長久以來，針對信賴保護原則之處理，學說不乏出現有關社會法治國原則之論述，蓋德國戰後社會法治國家圖像的成形，乃為信賴保護原則誕生之法制背景¹⁵。惟應予釐清者係，信賴保護原則之制度功能，顯然不在實現社會正義或確保社會安全；且其所涉及之權利種類，亦不以經社基本權為限。蓋信賴保護原則之創設，乃是探究國家得否對法秩序為不利人民之變更，故其所論及者，實為「國家高權侵益措施得否作成」之問題；且由於國家所為之侵益措施（例如：授益處分的撤銷、具溯及效力之不利新法），可能會導致人民既得權益受到過度侵犯，因此後續會有採行補救措施或訂定過渡期間條款之問題。

另有學說指出，法安定性乃作為拘束國家之客觀法秩序面向，至於信賴保護則專指人民之主觀請求面向而言¹⁶。對此見解，只要我們意識到信賴保護原則旨在處理國家高權侵益措施得否作成之問題，屬於「憲法基本權保障」之理念範疇，便可知悉其不僅作為人民對國家有所主張之主觀防禦權能，同時亦為國家權力所應服膺之「客觀價值決定」（objektive Wertentscheidungen）¹⁷。承此，立基於憲法基本權保障之信賴保護原則，實屬兼具主觀與客觀功能面向之

15 Ossenbühl (Fn. 1), S. 25 f.; Grabitz (Fn. 2), S. 675; Meyer (Fn. 1), § 48 Rn. 87.

16 Vogel (Fn. 1), S. 833 f.; Arnould (Fn. 1), S. 152 f.; Hartmut Maurer, Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV, 3. Aufl., 2006, S. 395 (397 f.); 司法院釋字第 574 號許玉秀大法官部分協同意見書；陳淳文，違法授益行政處分與信賴保護，收於：湯德宗、李建良編，2006 行政管制與行政爭訟，頁 22（2007 年）。

17 BVerfGE 7, 198 (198 ff.); Pieroth/Schlink (Fn. 14), S. 16, 20；李建良，基本權利理論體系之構成及其思考層次，收於：憲法理論與實踐（一），2 版，頁 58-65（2003 年）。

規範主張。

在確立信賴保護原則之理論基礎為「憲法基本權保障」之後，德國學說曾落入應以「何種」基本權來推導信賴保護原則之困局。有以基本法第2條第1項為基礎，認為憲法上自由之概念，除防範個人生活領域免於國家的介入危害，他方面亦及於國家公權力引起之人民行為可能性（*Handlungsmöglichkeit*）的擔保，用以促成最大可能機會的人格開展，而後者即為信賴保護之要旨所在¹⁸。另有見解以基本法第14條第1項之「財產權」（*Eigentum*）為依據，主張信賴保護的內涵，不僅指向既已取得、同時亦包含將為取得之財產法律地位，且其採行之保護方式（存續保障、價值保障），本質即為憲法財產權保障之功能體現¹⁹。上述見解雖言之成理，然而無論是立足於人格發展自由或財產權之觀點，皆會使信賴保護原則之適用受到侷限。蓋建構於憲法基本權保障之信賴保護原則，其旨在處理國家高權侵益措施得否作成之問題；基本權利有受到國家侵害之虞者，其種類並不以特定基本權為限，而是「任何」基本權皆屬可能²⁰，因此皆有受憲法保護之需要，從而並不宜以特定基本權來推導之。

綜觀上述所言，信賴保護原則之議題處理，無非就是憲法對基本權利的保障。因此，我們可以說：「在法治國家中，信賴保護即意謂著基本權利保障。」正因為源自於憲法基本權利保障，從而使信賴保護原則具有「憲法位階」，得以拘束國家公權力之行使，不論係立法或行政皆然²¹。

18 *Grabitz* (Fn. 2), S. 681 f.

19 *Schmidt* (Fn. 2), S. 532 ff.

20 *Kisker* (Fn. 7), S. 182.

21 為使討論焦點集中，本文以下有關信賴保護原則之探討係以「立法」及「行政」兩權為主，至於國家司法權行使下之信賴保護，則留待日後再為深論。

參、通說信賴保護原則要件審查模式之檢討

我國學界對信賴保護之檢視，一般咸以「信賴基礎」、「信賴表現」與「信賴值得保護」等要件審查流程，來逐步證立人民信賴利益之保護²²。故本文以下處理之對象，即在對此要件體系予以檢討。應予說明者係，在信賴保護原則之下位類型——「法規範不溯及既往」，因學說對其有不同之處理模式（詳後述），從而本文在此暫先不作討論。

一、信賴基礎

依學者所言，「信賴基礎」（Vertrauensgrundlage）必須是國家有對外創造出一特定之法外觀（Rechtsschein），足以引起人民對之投以必要之信賴，並按此法律狀態形成自身之生活²³。在此人民所信賴的對象，除了可作為信賴保護原則之成立要件外，其另一功能，便是決定後續信賴如何保護之法律效果——即應以信賴基礎所給予人民之期待為限²⁴。由於國家行為種類態樣繁多，因此得為信賴基礎者，包含抽象法規範與具體公權力措施²⁵，且該行為亦不以合法為必要²⁶。總之，關於信賴基礎的審查，學說基於人民信賴之保護，多對此一要件採取從寬認定之立場。

22 司法院釋字第 589 號解釋；吳庚，行政法之理論與實用，12 版，頁 66（2012 年）；林錫堯（註 1），頁 67；洪家殷，論信賴保護原則之適用——司法院大法官釋字第五二五號解釋評析，台灣本土法學雜誌，27 期，頁 42 以下（2001 年）；吳坤城，公法上信賴保護原則初探，收於：城仲模編，行政法之一般法律原則（二），頁 239-242（1997 年）。

23 林錫堯（註 1），頁 75；洪家殷（註 22），頁 42。

24 Stefan Muckel, Kriterien des verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes bei Gesetzesänderungen, 1989, S. 81。轉引自：林三欽，違法授益行政處分受益人之信賴保護——以金錢或可分物給付之授益行政處分為中心，中研院法學期刊，9 期，頁 10-11（2011 年）。

25 林合民（註 8），頁 67-68。

26 洪家殷（註 22），頁 42。

針對國家行為作為人民之信賴基礎，於此我們可以進一步追問的是：國家的無效行為（例如：具重大明顯瑕疵之行政處分、違法之法規命令與行政契約）、不具外部性的行政規則、不具法效性之行政事實行為、或者屬於私法性質之國庫行政，此類國家行為是否同樣能通過此一要件之檢驗。如答案為否定，其標準究竟何在；如答案皆為肯定，則信賴基礎之內容承載就顯然過於寬鬆，而有喪失「成立要件」係作為篩選、過濾之功能，有學者便指出，「在各種國家行為中，甚少不得成為人民信賴之對象者，因此檢討此項要件之具備與否，意義並不大。²⁷」

二、信賴表現

前述信賴基礎之闡述，僅在說明人民知悉國家行為之存在，並產生信賴之心理狀態而已。然而個人之內心情狀究屬為何，不僅認定不易，且甚難予以評價。有鑑於此，「信賴表現」（*Vertrauensbetätigung*）要件之出現，即在揭示對信賴保護而言，僅停留在單純之主觀信賴尚嫌不足，當事人須將此內心信賴形諸於外，形成客觀上得以察知之具體表現行為，包含特定計劃之安排或財產之處置，始足當之²⁸。此外，該對外表現應與信賴基礎間應具有因果關係，且限制在合理之範圍內（例如不尋常高額度的投資即非屬之），方為適當、合宜之信賴表現²⁹；而未有此客觀具體之信賴表現者，則僅為「單純之願望或期待」，自無主張信賴保護之餘地（司法院釋字第525號解釋參照）。

²⁷ 洪家殷（註22），頁43。

²⁸ *Maurer* (Fn. 4), § 8 Rn. 49; *Arnauld* (Fn. 1), S. 151 f.; *Paul Stelkens/Heinz Joachim Bonk/Michael Sachs*, *Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar*, 7. Aufl., 2008, § 48 Rn. 149; 林錫堯（註1），頁75；司法院釋字第668號陳新民大法官不同意見書。認為信賴表現亦及於「消極不作為」在內者：林明鏘，行政規則變動與信賴保護原則——兼評最高行政法院八十九年判字第一八四二號判決與大法官釋字第五二五號解釋，收於：林明鏘、葛克昌編，*行政法實務與理論*（一），頁589-590（2003年）；吳坤城（註22），頁240。

²⁹ *Meyer* (Fn. 1), § 48 Rn. 97; 林錫堯（註1），頁75；林三欽（註12），頁374。

以對外一定行為之表徵，作為內心存有信賴的明證，此雖係多數學者間之共識，惟在特定國家行為中，學說見解又顯得不盡一致。例如在「授益處分之撤銷或廢止」部分，學者有認為因行政處分具體個案之規制效力，得以形成一定之法律關係，從而處分的存在即足資作為人民應予保護之信賴利益，而毋須再論及有無信賴表現之必要³⁰；反之有學者指出，倘受益人未有任何表現於外之處置行為，將無以論斷人民因此所受之信賴損失³¹。而在「行政法規之廢止或變更」部分，學者考量行政法規僅係一般、抽象之規定，若無信賴表現作為判斷基準，將使信賴保護的範圍失之過廣³²；不同於此，通說在抽象法規變動之論述模型——法規範不溯及既往中，則向來有意忽略「信賴表現」之要件審查³³。

異於前者，有少數見解全然否定「信賴表現」作為信賴保護之要件。其認為對外表現雖有助於認定主觀信賴之有無，然不得因此即逆推出「無表現，即無信賴」之結論。蓋信賴既為國家所應保護之對象，則此信賴究以何種形式表現於外，應非信賴保護原則之重點所在，並且如何認定信賴表現與內心信賴間之關連，其標準亦非明確。再者，由信賴保護原則之理論基礎與現行法相關規定，均難以推導出有承認此一要件之必要；且由憲法平等原則以觀，僅保護有對外表現者之信賴，亦無法尋繹出此種差別待遇之正當基礎。承此，以信賴表現作為信賴保護原則之成立要件，恐易生人民信賴保護之脫漏，影響此原則功能之發揮，並不適宜³⁴。

30 李建良，從憲法觀點論軍公教優惠存款的存廢問題，收於：憲法理論與實踐（三），頁465（2004年）。

31 許宗力，行政處分，收於：翁岳生編，行政法（上），3版，頁544（2006年）；董保城，行政處分之撤銷與廢止，收於：臺灣行政法學會編，行政法爭議問題研究（上），頁479（2000年）；陳愛娥（註1），頁182。

32 李建良（註30），頁465。

33 以抽象法規作為信賴基礎時，毋須信賴表現之見解，請見：林明鏞（註28），頁589；林昱梅（註1），頁19。認為「在抽象的信賴保護類型，人民之信賴表現，亦不妨認為是虛構或推定的。」請見：林合民（註8），頁69。

34 洪家殷（註22），頁45-48。

本文認為，信賴表現與人民權益保護間之關聯，應視國家行為本身合法與否而作相異的處理。亦即人民權利的取得如為國家「合法」行為所賦予（例如合法授益處分、行政契約、法律與法規命令），則要求須有信賴表現始為保護，無異是對人民權利增加法律所無之限制，並非妥適。反之，權利如為國家「違法」授益處分所創設，基於處分相對人在此受有利益並非法規之原先意旨所在，毋寧係出於行政機關認事用法的違誤而意外獲致，從而當事人如未有因該處分而對外具體表現所致之權益損失，行政機關自得就該處分逕為撤銷，甚至不加補償亦屬無妨。例如考選部於辦理公職考試過程中，因各科分數加總錯誤，致本應落榜之考生A卻獲榜示錄取，設A選擇投身公務生涯而向原任職私人公司提出辭呈並且獲准，此等安排規劃將使主管機關嗣後撤銷權的發動受到嚴格限制；異於前者，如考選部發現作業疏失於翌日即致電通知，且此段期間內A亦無相關之對外具體表現，則縱為授益處分之撤銷，亦不致對A構成難以回復的重大損失。同理，在德國信賴保護原則的原初案例（Witwengeld案），一個依法不具請領撫卹金資格之公務員遺孀，因行政機關之違法授益處分而移居西柏林，並以此撫卹金作為維繫生活之經濟來源³⁵；倘該遺孀事實上未有「遷往他處」或「金錢花用」之對外具體表現，則對之撤銷亦無補償之必要。綜上所言，本文認為唯有違法授益處分，相對人須另具對外具體表現始能強化其權利保護需求，至於國家合法行為所創設之權利則不必如此³⁶。

三、信賴值得保護

對國家行為投以內心主觀信賴並產生一定具體表現行為後，在審查流程中，尚須合乎「信賴值得保護」要件，當事人之信賴保護

³⁵ BVerwG, NJW 1960, S. 692 (692 f.).

³⁶ 為獲知處分相對人有無及如何對外具體表現，本文建議行政機關在違法授益處分之職權撤銷前，必須給予相對人「陳述意見」之機會（行政程序法第 102 條）。

始能成立。惟何謂信賴值得保護，行政程序法第119條並未作正面之定義性規定，而是採行「負面列舉」之方式；亦即只要該當以下任一款事由，即排除當事人之信賴保護。

（一）以不正之方法而獲取處分者

行政機關違法授益處分之作成，如肇因於相對人以詐欺、脅迫或賄賂等方法所致（行政程序法第119條第1款），此際處分相對人因具有可歸責之事由，其權益自應排除保護之列，否則無異變相鼓勵非法³⁷；不過在具體個案中，本文建議宜進一步就處分相對人之違法情節輕重、不正方法與作成授益處分間之因果關係加以審酌，以合乎事理。例如B之博士論文因涉嫌抄襲且經查證屬實，由於其學位係以不正手段獲得，先前授予之博士資格，原就讀學校自得加以撤銷；不過如果B抄襲情形只是一、二處引述失當，且該博士論文之研究成果亦對學術具有一定之貢獻，則有無必要全盤否定相對人之付出，或許不無斟酌餘地。

（二）對重要事項提供不正確資訊或為不完全陳述而獲取處分者

此係指當事人對重要事項提供與事實不符之資訊，使處分機關產生誤導，並據此為違法授益處分之作成者而言（行政程序法第119條第2款）。承此，本款所指之「重要事項」，自應與作成授益處分所賴以為據之事實相關；倘非如此，則縱有不實資訊或不完全陳述等情事，亦不能因此而排除當事人之信賴保護。

不過，此等規定與前款以「詐欺」方法使行政處分之作成，在內涵上究有何異，容有辨明之空間。再者，本於公益的維護，行政機關對事實真相之探知，係採「職權調查主義」。申言之，相關事項之證據調查，倘為行政機關之權責範圍，此際應對當事人有利及

³⁷ Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 28), § 48 Rn. 150 ff.

不利部分一律注意，並不受當事人主張之拘束（行政程序法第36條）。於此當不能以受益人之陳述不完全，即逕認其信賴不值得保護³⁸。此等見解，於「社會行政」領域尤具意義。蓋於申請社會給付之相對人，多為教育程度或身心發展較為不足之弱勢族群，其對抽象條文意涵之掌握、自身處境資訊之統合、以及言語之理解表達上，極易與申請機關產生認知上落差，倘動輒認其構成「提供不正確資料或為不完全陳述」，而為授益處分之撤銷並下命原先給付之返還，勢將使該弱勢族群之生活無以為繼，而有欠妥適³⁹。是以在本款之情形，當事人本身雖有可歸責之事由，惟是否應一律劃歸為信賴不值得保護，可能須視個案情形綜合判斷之，不宜一概而論。

（三）明知或因重大過失不知處分違法者

信賴保護原則如著重於「內心主觀信賴」之保護，則處分違法情形倘為受益人明知或可得而知，由於其可預見處分將遭到撤銷之命運，自無信賴可言；倘仍對之投以信賴，自應不予保護⁴⁰。不過此等解釋在現行條文的操作下，可能會導致相對人無所適從而蒙受難以估計之損失，於此試舉一例如下：

設C在風景區購得一建地，準備興建占地千坪之山莊飯店，由於建管機關現場履勘人員未就該址之地勢坡度走向詳加調查，致機關內部承辦人員為建築執照之核發，而此一違法情形亦為C事後所察知。此際，C面臨之難題是：倘立即發包動工，因C知悉該處分

38 蔡宗珍，撤銷違法行政處分之限制——信賴保護之主張及其效力，月旦法學教室，63期，頁88-89（2008年）；陳淳文（註16），頁30-32。

最高法院93年度判字第1359號判決：「原處分機關之作成行政處分，就調查證據認定事實有十足之權限，非依恃受益人所提供之資料或陳述者，縱受益人提供之資料或陳述出於不正確或不完全，仍不得據以謂其信賴不值得保護，而撤銷違法之行政處分。」

39 孫迺翊，社會給付行政中受益人之信賴利益保護——以德國社會行政程序法為借鏡，輔仁法學，37期，頁151（2009年）。

40 Meyer (Fn. 1), § 48 Rn. 88.

為違法，屬於信賴不值得保護，處分機關自得撤銷該違法處分，並拆除興建中之建物，而毋須補償C的損失；並且因該建照之核發，完全滿足C當初之申請，屬於「授予利益之行政處分」，是以C亦不得循行政爭訟管道訴請撤銷（訴願法第1條第1項、行政訴訟法第4條第1項：「損害其權利或法律上之利益」），而事後再申請建管機關為另一「合法」建照之發給。在此情況下，C唯一能做的，便是靜待行政機關撤銷權行使之二年除斥期間經過，始能決定之後的安排……。

然而，在一個講求效率的工商社會，如此法律關係的懸而未決，對當事人權利的影響，可能遠比當初直接「否准申請」還要來得嚴重。縱觀整個事件的發展始末，建照處分之所以違法，係來自於機關內部之作業疏失，C僅止於知悉而已，盡將所有不利益歸其承擔，未免不公⁴¹。由此可知，在現行法操作下所呈現的利益狀態，對人民權利保護之考慮實有欠周到，容有檢討與改進之必要。

四、小結

以信賴基礎、信賴表現及信賴值得保護建構而出之要件審查體系，雖為學界多數所肯認，惟就「信賴基礎」部分，倘涉及抽象法規範（法律、法規命令）之不利變更，學者向來跳脫此一要件審查架構，而另循「法律不溯及既往」模式闡述之；而在「信賴表現」之要件設定與範圍認定，學說見解又眾說紛紜而缺乏共識；另於「信賴值得保護」部分，此要件之設定顯然建立在國家行為係屬「違法」之前提上，從而信賴基礎如為合法授益處分、行政契約、行政計畫、行政事實行為或行政法規，應否進行該要件之檢視，即可置疑。是以嚴格來說，信賴保護原則迄今仍未發展出足資一體適用所有國家行為之要件審查體系。

41 另請參見：陳淳文（註16），頁43，註腳95。

尤有甚者，參酌上述之學說爭議，可知現行信賴保護原則之課題重心，究竟指向：內心主觀信賴之保護⁴²、信賴利益之保護⁴³、或者信賴損失之保護⁴⁴，根本缺乏一明確的置準。甚且如果我們仔細的話，便可發現上述所有要件之檢視對象，皆是指向「人民」而非國家。然而有問題的是，國家變動現行有效之法秩序，可能會對人民之既得權益產生不利之影響，則針對國家侵益措施的採行，何以其要件之設定，可以全然脫免「法律保留原則」與「比例原則」之檢驗，而只將整個審查重心圍繞在人民之信賴上做打轉，如此安排顯然有誤。如前所述，信賴保護原則旨在探究國家得否對法秩序為不利人民之變更，屬於憲法基本權利保障之課題。承此本文以下之嘗試，即以憲法基本權保障為基礎，從人民「公權利」之觀點出發，並將現行信賴保護原則之主要審查對象，由「人民」轉移至「國家」，進而充填國家變動既存法秩序所應具備之要件審查架構，用以落實憲法對基本權保障之理念意旨。

肆、信賴保護原則的要件重構

我國信賴保護原則之指標案例——司法院釋字第525號解釋，其於解釋文中開宗明義指出：「信賴保護原則攸關憲法上人民權利之保障……。」權利存在的探尋，實為公法學的一切基礎與核心要務，其決定著人民與國家間法律關係之分際、衍生而來之權利保護內涵、以及有無接近法院尋求救濟之訴訟權能。是以，本文認為信賴保護原則之思維應改弦更張，由信賴保護調整為「公權利保

42 認為法秩序的持續與穩定，人民始能在此基礎上投以信賴；行政程序法第119條第3款規定（主觀上）明知或可得而知處分違法者，其信賴即不值得保護。

43 排除主觀上單純願望、期待或情感上利益，僅保障因信賴所生之「實體法上利益」（司法院釋字第525號解釋參照）。

44 信賴表現之要件設定，或認為信賴保護本質上即為「處置保護」（Dispositionsschutz）。

護」，並以此為新審查架構之開展。值得一提者係，此等審查架構之安排，並非筆者個人別出心裁之創意，而是我們再熟悉不過的「基本權審查模式」⁴⁵，在此加以沿用而已。

一、公權利的存在

（一）概論

權利者，乃得享受特定利益的法律之力。此等法律狀態之存在，係賦予權利主體請求相對人為一定作為或不作為，並得循訴訟途徑加以救濟，以促成個人法益之實現；而由公法所創設之權利，賦予人民一定之法律地位與權能，即可稱之為「公權利」⁴⁶。在此要件設定之下，法治國家所應保護的對象，即為國家行為在法秩序中有無創設公權利之客觀認定，至於反射利益、情感上利益（單純主觀願望或期待），則不與焉。而人民的公權利既為法治國家之課題重心，且其來源可由憲法文本之揭示與解釋、立法者之初步形塑、或者公行政的具體作成而產生⁴⁷，則探尋公權利之存在實與檢視國家行為無異。換言之，此要件具有取代通說有關「信賴基礎」與「信賴利益」要件之功能。

此外，司法院釋字第525號解釋中指出，國家法秩序的修改致人民因信賴而生之實體法上利益受損害，應採取合理之補救措施以為因應。在此僅論及人民之「實體法上利益」，是否有排除保護「程序法上利益」之意旨，未可知之。雖然歐陸法系向有「重實體而輕程序」之歷史傳統，不過隨著現行法制下「程序正義」之意識

45 Pieroth/Schlink (Fn. 14), S. 49 ff.; 許宗力，基本權的保障與限制（上），月旦法學教室，11期，頁64以下（2003年）（以下簡稱：許宗力，基本權（上））；許宗力，基本權的保障與限制（下），月旦法學教室，14期，頁50以下（2003年）（以下簡稱：許宗力，基本權（下））；李建良（註17），頁71以下。

46 Maurer (Fn. 1), § 8 Rn. 2 ff.

47 Hans J. Wolff/Otto Bachoff/Rolf Stober/Winfried Kluth, Verwaltungsrecht I, 12. Aufl., 2007, § 40 Rn. 8.

逐漸抬頭，經立法者明文承認之程序利益，如不予保護實有商榷餘地⁴⁸。對此見解本文認為應可贊同，不過考量程序的踐履攸關行政與司法資源之耗費，因而對程序利益尚未構成重大限制，自宜在比例原則中放寬審查密度，尊重立法者對此國家資源配置的形成自由。

值得一提的是，本文認為在從事權利有無之認定時，應特別斟酌當事人是否構成「惡意取得權利」。所謂「惡意」，並非指向當事人主觀上之明知或可得而知，而係指權利來源係以非法或不正手段而取得。從而授益處分之作成倘導因於機關內部認事用法之違失，相對人僅止於處分違法性之單純知悉，於此尚不足以惡意稱之。反之，當事人預見給付性或優惠性法律即將修正廢止，藉機搶搭末班車以攫取權利⁴⁹；為取得授益處分而偽變造資料、就申請重要事項為故意之欺瞞誤導、或私下與機關公務員串通勾結，於此皆屬惡意取得權利之適例。權利倘為惡意取得，當事人在客觀上仍握有權利，只是本於「惡意不受保護」之法理，將在比例原則階段弱化當事人之權利保護需求（採取較寬鬆之審查基準），關於其損失亦毋須給予金錢補償或採行其他補救措施之必要；甚至原授益處分的內容倘涉及金錢或可分物之給付者，於該處分溯及既往失效時，受益人應依「惡意受領人」之標準，返還因該處分所受領之全部給付（行政程序法第127條第2項準用民法第182條第2項）。

（二）具體之行政行為

學說以法安定性原則推之，而認為一切國家對外行為，人民因可對之投以信賴，從而皆有信賴保護原則適用；惟倘改以憲法基本

48 洪家殷（註22），頁48-49；林明鏘（註28），頁590-591。

不同見解：認為「程序規定」原則不涉及實體之權利義務，如遇有變更亦應適用新規定，並不生信賴保護之問題，請見陳敏（註1），頁91。

49 陳新民（註1），頁190；李建良（註1），頁86。

權保障為基礎，能否獲致同樣之結論，則有待商榷評估。依此，茲將國家可能採行之具體措施，分述如下。

1. 授益處分

在行政法學中，行政處分向為行政機關行為型式之典型。其特色在於：行政機關得單方直接創設規制效力，具體化個案中公行政主體與人民間之法律關係。行政處分的法效果如為相對人創設一定之權利者，例如外籍人士歸化之許可、准予專技人員考試報名之申請，或者是行政機關對負擔處分之撤銷廢止，皆可歸類為「授益處分」之範疇。於此國家所應保護者，即非人民對授益處分所投以之主觀信賴、或因此而生之生活計畫安排，而是授益處分本身之「法效性」（*Wirksamkeit*），也就是在法秩序中產生授予利益之法律效果，進而成為處分相對人公權利存在的客觀依據⁵⁰。又具備法效性之處分並不以合法為限，違法處分亦然（行政程序法第110條第3項），因此皆為法治國所應保護之對象；至於自始、當然欠缺法效性之「無效行政處分」，因其無從導出公權利，則應排除信賴保護（憲法基本權保障）適用之可能。

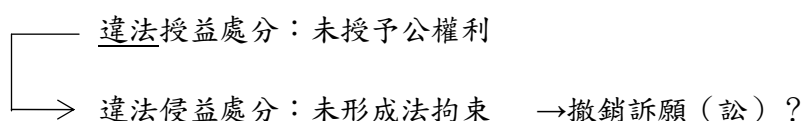
有學者指出因處分係屬「違法」，從而違法授益處分不能作為相對人享有利益與優惠之法律地位⁵¹。對此本文認為，違法授益處分如未授予相對人公權利，則如何判定其屬「授益」處分，又其法效性究竟何在，令人費解；且沿續此見解之脈絡，似可反面推之「違法侵益處分」因同屬違法，從而對人民權利亦未形成法拘束，如此專門排除違法侵益處分效力以維護人民權利保障之「撤銷訴願（訟）」，其制度功能勢將受到架空而顯多餘（參見下圖1）。上述學

⁵⁰ Hans-Uwe Erichsen, Die Aufhebung von Verwaltungsakten durch die Verwaltung, Jura 1981, S. 534 (537); Barbara Remmert, Verwaltungsrechtsverhältnis, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl., 2010, § 18 Rn. 9.

⁵¹ Püttner (Fn. 4), S. 204; Maurer (Fn. 16), § 79 Rn. 97.

說不僅背離違法處分亦具法效性之概念設定，同時亦忽略行政處分對法律關係（權利義務關係）的建立，其見解自非可採。

圖1 違法授益處分倘未授予公權利之影響



資料來源：作者自製。

（1）具混合效力之行政處分

關於人民有關授益事項之申請，處分機關作成同時產生授益與負擔效果之決定者，即屬「具混合效力之行政處分」（*der Verwaltungsakt mit Mischwirkung*）。例如申請數額為200萬之貸款而只核准100萬，此處分即蘊含貸款100萬之准許與另100萬之拒絕等雙重效力⁵²。關於此種處分之廢棄，究應以授益或負擔處分處理，實有討論之必要。一般而言，首應判斷行政處分於此之法律效力是否可分而定：如為可分（例如授益處分另有「負擔」附款之添加），則各依其對處分相對人之效果為何，而分別適用不同之規定；反之如為不可分，基於處分相對人之信賴（公權利）保護，應將此處分之混合效力視為整體，一體適用關於「授益處分」廢棄之規定，以限制行政機關在此廢棄權限之行使⁵³。

除上之外，誠如學者所言：「單純負擔處分之廢棄因對人民有

⁵² 許宗力（註31），頁505。

⁵³ *Erichsen* (Fn. 50), S. 538; *Carl Hermann Ule/Hans-Werner Laubinger*, *Verwaltungsverfahrenrecht*, 4. Aufl., 1995, § 61 Rn. 27; *Ferdinand O. Kopp/Ulrich Ramsauer*, *Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar*, 12. Aufl., 2011, § 48 Rn. 72; 洪家殷，行政處分撤銷之研究，國立政治大學法律研究所博士論文，頁152（1992年）；董保城（註31），頁476-477；林三欽（註12），頁365。

利，固毋須納入信賴保護原則之考量；惟在某些形式上雖為負擔處分者，特別是適用優惠稅率之核課處分，就該優惠部分而言實屬授益，故其兼有負擔與授益之雙重效果。若撤銷該處分中之優惠部分，實與撤銷授益處分無異，亦應有信賴保護原則之適用⁵⁴。」此即意謂該「兼具授益效果之負擔處分」，亦可視為具混合效力之行政處分之一種：即先探究該處分之法律效力是否可分，其次判斷該處分之廢棄是否構成公權利之侵害，進而決定其有無接受合憲審查之必要。

（2）具第三人效力之行政處分

所謂「具第三人效力之行政處分」，係指行政機關作成之行政處分，使處分相對人與第三人間產生利害衝突而言。依其利害歸屬對象之不同，學說將此處分再分類為兩種情形，於此分述如下。

首先是「具第三人負擔效果之授益處分」，其意指處分雖授予相對人利益，卻為第三人帶來不利之影響而言，此常見於建築法鄰人與競爭法同業間。對於此種處分之撤銷，通說傾向以「授益處分」來處理，蓋受益人對是否存有不利益第三人之情形可能無所知悉，不能因第三人受有不利益，即可排除受益人之信賴利益保護⁵⁵。惟有學者依德國聯邦行政程序法第50條之規定，指出處分雖授予相對人利益，惟因處分隨時有可能因第三人提起行政爭訟而遭撤銷，此等情形應為受益人所預見或可得預見，故於第三人之法定救濟期

54 許宗力（註31），頁506；林昱梅，地價稅之回溯補徵與信賴保護原則，月旦法學教室，53期，頁27（2007年）。同此見解：盛子龍，租稅核課處分之不利變更與信賴保護——試評高雄高等行政法院91年度訴字第891號判決，收於：王必芳編，2008行政管制與行政爭訟，頁177-180（2009年）。

55 Erichsen (Fn. 50), S. 539；洪家殷（註53），頁154-156。不同見解：認為此該處分因構成對第三人基本權之違法侵害，從而應以「負擔處分」視之，行政機關負有撤銷之義務，參見 Schenke (Fn. 12), S. 323 f.

間內，受益人並無信賴保護可言⁵⁶。另有學者主張受益人在知悉第三人提起行政爭訟後，因行政處分將來之存續已陷於不確定，受益人當有義務了解該處分本身之合法性，故在此時點之後所從事之信賴表現行為，可視情形而認為信賴不值得保護⁵⁷。

其次是「具第三人受益效果之負擔處分」，其指行政機關以處分課予相對人負擔時，卻同時為第三人帶來利益，例如下命屋主拆除違建，而保障了鄰人之生命財產安全。針對此該處分之撤銷，多數見解認為其應以負擔處分撤銷之法理適用之，蓋第三人應非行政程序法第117條第2款之「受益人」，其利害關係並非處分作成之主要目的，且第三人因處分違法所獲致者僅為「反射利益」而已⁵⁸。惟行政機關作成該處分之法律依據，倘其兼有保護第三人權利之意旨時（保護規範理論），第三人自得於該處分經撤銷後，藉由「課予義務訴訟」請求新處分之作成，而同樣達到其權利保護之目的⁵⁹。

實則上述爭議的產生，是因學說將信賴保護定位在「內心主觀信賴保護」所致。從而考量利害關係人之存在、或其行政爭訟的提

56 Maurer (Fn. 1), § 11 Rn. 67; Schenke (Fn. 12), S. 323；李建良，論行政處分之違法判斷基準時，收於：臺灣行政法學會編，行政法爭議問題研究（下），頁 931-932（2000 年）；董保城（註 31），頁 491；林錫堯（註 1），頁 353-354。

本文認為，第三人訴請撤銷之事實如能預見或可得預見，必建立在受益人知悉處分本身係屬違法之前提上，方能得知處分恐遭撤銷之命運；然而處分之違法性倘為受益人所明知或可得而知，在現行法的規定下，將直接使受益人之信賴不值得保護（行政程序法第 119 條第 3 款）。其次，在具第三人負擔效果之授益處分，利害關係人之法定救濟期間，並非處分生效後起算三十天，而係處分生效後三年內知悉處分存在之三十天（訴願法第 14 條第 2 項）；必須等待三年期間經過後才開始處分相對人之信賴保護，如此恐有過度弱化處分相對人（受益人）權利保護之嫌。

57 林三欽（註 12），頁 381。本文認為，參酌第三人撤銷訴願（訟）中，其被告為「處分機關」而非處分相對人，加上第三人訴請撤銷之事實縱為受益人所知悉，惟處分最終是否遭訴願機關或行政法院撤銷，則尚在未定之天，從而可能不宜因第三人行行政爭訟的提起，即影響處分相對人本應受之權利保護。

58 李庭熙，論附第三人效力之行政處分，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 35（1990 年）；林三欽（註 12），頁 367；洪家殷（註 53），頁 156-158。

59 Erichsen (Fn. 50), S. 539; Wolff/Bachoff/Stober/Kluth (Fn. 47), § 43 Rn. 17 ff.

起，可能會動搖處分相對人之內心主觀信賴，因而處分之撤銷究應適用授益或負擔處分之法理，自不能將第三人之因素排除在外。不過值得注意者係，在此關於信賴保護之處理，學者還是回到公法學既有之權利體系（公權利與反射利益之二分）、保護規範理論等概念，來尋求系爭問題之解答。

不同於前，本文認為信賴保護原則之理論基礎旨在「**憲法基本權保障**」。其於授益處分中，係以行政處分的法效性來判斷相對人之公權利存在；而行政機關就該處分撤銷權限之行使，則取決於有無構成相對人公權利之侵害⁶⁰；至於非處分法效所欲規制之第三人，其利害關係則應納入「公益」的內涵組成，而於比例原則中加以審酌⁶¹。綜上所言，關於「具第三人效力之行政處分」的處理，其本質即為「**公權利受干預合憲審查**」之流程思考。

2. 行政契約

行政契約係指兩個以上之權利主體，以設定、變更或消滅「公法上法律關係」為目的，因意思合致而成立之行政行為（行政程序法第135條參照）⁶²。行政契約之訂定使行政法上之權利義務產生得喪變更，締約人民得以此公法上法律關係請求締約機關履行契約給付，從而行政契約自得作為對國家有所主張之「公權利」。不過鑑於行政契約可能存在國家出賣公權力，或以優勢地位欺壓相對人而獲取契約合意等種種弊端，為避免行政契約的濫用，倘其內容具有法定列舉之無效事由者（行政程序法第141、142條參照），此等瑕疵將使行政契約自始、當然、確定之不生效力，而不生補正或瑕

⁶⁰ 正確之見解：關於具第三人效力之行政處分撤銷之處理，應直接以處分相對人之效果而定。請見 *Erichsen* (Fn. 50), S. 539；洪家殷（註53），頁158；董保城（註31），頁477。

⁶¹ *Maurer* (Fn. 1), § 11 Rn. 68.

⁶² 林明鏞，行政契約，收於：翁岳生編，行政法（上），3版，頁561（2006年）。

疵治療之問題⁶³。行政契約如為無效，自不能創設或改變任何公法上法律關係，於此締約人民自無公權利可資主張，而應排除信賴（公權利）保護適用之可能。

3. 行政計畫

行政計畫係公權力主體為於一定期間內為特定行政目的之達成，事先就其決策所為之設計或規劃，藉以整合多元利益、提高國家施政透明與效能之一種行政行為。行政機關倘依特定法規（如都市計畫法、區域計畫法）作成具有規範效力之行政計畫（司法院釋字第513號解釋參照）；或者計畫內容涉及一定地區土地之特定利用或重大公共設施之設置，而攸關多數不同利益之人及多數不同行政機關權限者，於經公開及聽證程序後，得依行政程序法第164條第1項規定作成「確定計畫裁決」（Planfeststellungsbeschluss），此種行政機關單方對特定或可得特定之人直接發生法律效果之准否決定，其定位應屬「行政處分」⁶⁴。上開公權力措施之法效果倘對人民有利，自得以此作為人民公權利存在的立論依據。

4. 行政事實行為

所謂行政事實行為，係指行政機關在其職權所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，而發生事實效果之行政措施。行政機關對外作成之行政事實行為中具授益性質者，計有「資訊提供行為」與「財貨供給行為」兩種。不過因其無從在法秩序中為人民創設出主觀公權利，從而本文否定人民得依「行政事實行為」主張信賴（公權利）保護⁶⁵，詳細如下。

63 林明鏘（註62），頁590。

64 *Wolff/Bachof/Stober/Kluth* (Fn. 47), § 56 Rn. 19; *Fritz Ossenbühl*, *Staatshaftungsrecht*, 5. Aufl., 1998, S. 386; 陳敏（註1），頁650；董保城，行政計畫，收於：翁岳生編，*行政法（上）*，3版，頁607（2006年）。

65 另請參見：陳春生，事實行為，收於：翁岳生編，*行政法（下）*，3版，頁7（2006年）。

行政機關「資訊提供」之事實行為中，其方式包含為實現一定行政目的，而對外所為之個別通知或公告發布（例如公布市售食品有毒物質添加之消息）。此類國家行為之目的因僅在使人民知悉，而非在法律狀態上賦予其公權利；並且行政機關發布之資訊如與事實不符，進而侵犯當事人之公權利（例如商譽受損、營收銳減），則此等國家高權行為所引發者，主要係結果除去請求權或國家賠償請求權之問題，而與屬行政損失填補之信賴保護無涉⁶⁶。

其次，關於行政機關「財貨供給」之行政事實行為中，倘國家現實提出財產給付，受益人欠缺受領此等財產給付之法律上原因（例如：冒領、溢領、行政機關錯誤付款、或行政程序法第127條第1項之授益處分溯及失效），依法將構成「公法上不當得利」（*Erstattungsanspruch*）⁶⁷，受益人即負有返還原先財產給付之義務。由上可知，受益人單純受領國家財產給付之事實，並不足以為其創造出值得保護之法律地位（公權利），從而人民不得以「信賴保護」為由拒絕返還之；也唯有具備「法律上原因」（行政處分、行政契約），受益人始能享有終局取得並保有該財產利益之正當性。

5. 行政上之承諾

所謂「承諾」（*Zusagen*），係指行政機關自我拘束於日後將為一定處置、容忍或不作為之聲明或表示。如果將信賴保護定位在「內心主觀信賴保護」，則人民以此作為信賴基礎，似無不許之理⁶⁸；惟本文認為此等行政機關自行所為之義務承擔，能否因此導

⁶⁶ *Wolff/Bachof/Stober/Kluth* (Fn. 47), § 57 Rn. 33 f.; *Maurer* (Fn. 1), § 15 Rn. 6.

⁶⁷ *Ossenbühl* (Fn. 64), S. 425 f.; 林明昕，「公法上不當得利」之體系性思考，收於：公法學的開拓線——理論、實務與體系之建構，頁 243（2006 年）。

⁶⁸ 肯定見解：*Ossenbühl* (Fn. 1), S. 28 f.; *Schmidt* (Fn. 2), S. 536; *Püttner* (Fn. 4), S. 213; *Wolff/Bachof/Stober/Kluth* (Fn. 47), § 53 Rn. 23；否定行政上承諾有信賴保護原則適用者：*Maurer* (Fn. 16), § 79 Rn. 114 ff.

出人民享有相對應之公權利，必須視該承諾之法律性質加以判定。亦即行政上之承諾如為行政處分、行政契約者，當事人之權利保護自應回歸前述相關行政行為型式處理之；反之，系爭國家措施如為不具法效性之非型式化行政行為，例如向洽公民眾承諾以最速件辦理、或政府保證股市上萬點，則人民主張國家應言出必行或在道德上講信用，此等請求顯非法治國家原則之內涵所能承載，亦非依「法」審判之司法者所得實現。承上以言，關於行政上承諾之處理，仍宜回歸行政行為型式屬性之檢視，始能判斷有無信賴保護原則之適用餘地。

6. 國庫行政行為

屬於私法性質之國庫行政行為，其能否作為人民之信賴基礎，似未見有相關之文獻討論。不過，如果由「憲法基本權保障」之脈絡切入，其肯否之回答實已清楚浮現。雖然為避免國家規避公法而遁入私法之弊端，國家放下統治高權主體姿態、捨棄典型之公法形式手段，仍應有憲法基本權規定——特別是平等原則之適用（司法院釋字第457號解釋參照）⁶⁹；惟此「基本權利的國庫效力」僅係作為對國家之客觀拘束，人民在此私法關係中所形塑而出之權利態樣，依舊為「私法上之權利」。既非公權利，當與憲法基本權之主觀防禦功能無涉，於此人民對國家有關私權保護之請求權基礎，自應援用私法規定加以主張（例如：民法第91、245之1、247條），而與公法上信賴保護原則無涉。

（三）抽象之法規範

一般而言，國家作成之抽象法規範，計有法律、法規命令、與行政規則等態樣。至於饒富爭議的「職權命令」（例如司法院釋字第717號解釋之釋憲標的），其性質究屬行政命令之第三種類型或實

⁶⁹ 許宗力（註14），頁40以下。

為行政規則，學說見解仍未明朗；考量其非本文之脈絡主軸，加上現階段筆者對此概念的理解仍未成熟，於此則暫略過不論。

1. 法律、法規命令

信賴保護原則之理論基礎既源於憲法基本權之防禦面向，則鑑於法治國家中立法者有積極落實憲法基本權保障，而對權利加以具體形成之優先權限，是以認定人民公權利之有無，自應以「法律」之明文規定為首要。此外法律之制定雖為立法者之固有權限，惟考量立法者自身專業知識之不足以及法律訂定過程之冗長繁瑣，故法治國家中肯認立法者得出於專業分工、即時因應情勢變遷之需求，以授權之方式使行政部門享有部分之規範制定權限⁷⁰。而立法者在此授權之事項與方式，倘合乎「法律保留原則」（司法院釋字第443號理由書參照）與「授權明確性」（司法院釋字第313、394、522、612、680號解釋參照）之要求，則行政機關基於此該法律之授權，對多數不特定人民就一般事項所作抽象之對外發生法律效果之「法規命令」（行政程序法第150條第1項），亦得以此作為人民主觀公權利存在之法規依據。

司法院釋字第525號解釋文中提及：「法規如預先定有施行期間者，乃不生信賴保護之問題。」此等見解正確之處，在於作為創設人民公權利之法律或法規命令，倘於規範制定之初即預先設有一定存在時限（含落日條款），則人民權利的屆時喪失，乃出於權利本身之內在存續期間所致，而與國家侵害行為無涉，自非奠基於憲法基本權保障之信賴保護所欲處理的課題範疇⁷¹。其次，解釋文中另指出：「經廢止或變更之法規有重大明顯違反上位規範情形，……

⁷⁰ 陳敏（註1），頁542以下。

⁷¹ 惟具授益性質之限時法倘「提前失效」，於此即有人民權益保護之問題。請見張文郁，限時法和法律之溯及既往，收於：權利與救濟（二），頁37-38（2009年）。

其信賴即不值得保護。」法規倘生重大明顯違反上位規範之情事，其效果向以「無效」評價之；一個自始欠缺法律效果之抽象法規，無從在法秩序中為人民創設出公權利，從而當無保護之必要⁷²。

值得一提者係，針對抽象法規中「權利」之理解，許宗力大法官嘗試提出「依舊法已取得之權益」與「依舊法預期可取得之權益」之概念二分。其認為一個持續進行之事實關係中產生法秩序之變動，必須視人民權益取得之情形而給予程度不等之信賴保護。而關於依舊法預期可取得權益之認定，應就「重要之要件是否已具備、未具備之要件能否在客觀上合理期待其實現、或經由當事人繼續施以主觀努力後而有實現之可能性等因素綜合判斷之。」倘取得該利益重要要件之實現在客觀上非可合理期待、或處於當事人無法掌握之不確定狀態，或者權益之取得根本非當事人所預設之目標，則此階段當事人之地位，即不具期待權之性質，僅能以主觀願望或期待視之，當無要求信賴保護原則之適用⁷³。

針對許大法官所提出既得權與期待權之分類，學者陳愛娥認為此等援引自民事法中既得權與期待權之制度概念，其憲法基礎究竟何在？特別是信賴保護之範疇倘及於人民尚未取得之期待權，勢必會壓縮立法者配合時代變遷之形成空間⁷⁴。對此本文亦認為，權利之取得如果來自所有要件的全部合致，則理論上任一要件皆屬重要；並且倘以眾多因素綜合考量之方式來論斷期待權與主觀期待間之分際，可能會因重要與否取捨的不同，而在評價結果上出現歧異，使信賴保護原則的處理欠缺穩定。除此之外，權利向為公法學之核心概念，何以在信賴保護原則之領域，國家須另保護一個尚未

72 不同見解：認為其理由在於此種無效行為，受規範者不能諉為不知而主張信賴信護，請見吳庚（註22），頁65。

73 司法院釋字第574號許宗力大法官協同意見書參照。值得注意者係，此等見解後來為司法院釋字第605號之多數意見所採用。

74 陳愛娥（註1），頁166。

取得之期待權，實不免突兀；甚且權利如果都尚未取得，則國家行為有無構成「權利」之侵害、人民有無尋求法院救濟之「訴權」、或得否以此聲請大法官解釋，都不免讓人質疑。出於上述幾點之考量，許大法官既得權與期待權之區分，並未為本文所採。

2. 行政規則

以機關公務員作為規範對象，而被定位為「行政內規」之行政規則，得否作為人民之信賴基礎，學者見解在此可謂肯否參半。肯定說認為行政規則倘一經公開發布，人民對之投以信賴而安排生活或處置財產時，國家自不容對此一情形加以忽視⁷⁵；否定見解則因行政規則本身係欠缺直接對外法效果之法源依據，是以應排除人民在此之信賴保護⁷⁶。由於本文認為信賴保護原則之理論基礎係為「憲法基本權保障」，屬於公權利保護而非內心主觀信賴保護，從而主張行政規則宜排除信賴保護原則之適用，其理由說明如下。

（1）組織性、作業性行政規則

公權力主體以行政規則之形式具體化機關內部之組織秩序，其旨在對內作行政體制之安排，用以貫徹行政一體之上下指揮監督，此等規範機關內部之「組織性行政規則」，實無涉人民之自由權利。承此國家組織結構的改造更替，例如單位的裁撤或機關位址之

⁷⁵ Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 28), § 40 Rn. 113; Püttner (Fn. 4), S. 216 f.; 司法院釋字第 525、529、538、605 號解釋參照；林錫堯（註 1），頁 78；洪家殷（註 22），頁 43；黃俊杰，解釋函令變更與信賴保護——行政法院八十八年度判字第三九〇七號判決評釋，台灣本土法學雜誌，20 期，頁 8（2001 年）；林三欽，行政法令變遷與信賴保護——論行政機關處理新舊法秩序交替問題之原則，收於：「行政爭訟制度」與「信賴保護原則」之課題，頁 325 以下（2008 年）；陳清秀，稅法上行政規則之變更與信賴保護，法學新論，18 期，頁 54（2010 年）。

⁷⁶ Ossenbühl (Fn. 1), S. 29; Schmidt (Fn. 2), S. 530; Maurer (Fn. 16), § 79 Rn. 123; Wolff/Bachoff/Stober/Kluth (Fn. 47), § 24 Rn. 27；林明鏘（註 28），頁 585-586；陳愛娥（註 1），頁 187；吳庚（註 22），頁 67；蔡宗珍（註 1），頁 128。

遷移，縱為人民帶來不便，亦不生對人民公權利之侵害⁷⁷。其次，行政部門就機關內部事務分配、業務流程處理或人事管理所為之「作業性行政規則」，此等專以統籌機關內部組織運作，並以下級機關或公務員為對象之一般、抽象規定，乃屬傳統之「國家內部領域事項」。從而人民應無以作業性行政規則為依據，請求行政機關為一定處置或尋求司法介入干預之主觀公權利存在，於此亦與憲法基本權利保障無涉。

（2）解釋性、裁量性行政規則

主管機關基於職權，為澄清法規上之疑義、統一法令的解釋，用以闡釋法規意旨，防免處理結果分歧並增進行政效能之「解釋性行政規則」⁷⁸；或提供機關公務員裁量權行使之標準或模式，以促成個案執法穩定妥當之「裁量性行政規則」⁷⁹，此等欠缺直接對外法效力之行政內規，其對人民權利義務產生影響並非來自於規定本身，而是導因於執法機關對其適用之結果。換言之，有利於人民之解釋性與裁量性行政規則，並不足以作為證立人民存有主觀公權利之規範基礎，因而國家嗣後對此等行政規則之修正變更，亦無涉權利之侵害，自無開啟公權利受侵害之合憲性判斷的必要。

不過可想而知者係，在解釋性或裁量性行政規則修正變更後，相較於先前的行政實務（法規適用），必然會出現相同事件而為不同處理之差別待遇，形成法律適用上的不平等，於此所進行者應係「平等原則」之審查。在此，「行政機關倘非基於公益考量，僅為行政上一時權宜之計，或出於對部分對象為不合理之差別對待，或其

77 蕭文生，基本權利侵害之救濟，收於：李建良、簡資修編，憲法解釋之理論與實務（二），頁473（2000年）。

78 應予說明者係，此處所指之解釋性行政規則，其型態及於我國實務常見之「解釋函令」（釋示）在內（司法院釋字第548號解釋理由書參照）。

79 陳敏（註1），頁543-544。

他非屬正當之動機而恣意廢止或限制法規適用者」(司法院釋字第525號解釋理由書參照)，人民自得透過平等原則或行政自我拘束原則之援引，主張系爭前後不一的「處理結果」構成違法，以之請求行政機關應依先前模式比照辦理，而獲享等同之待遇⁸⁰。除非修正前之行政規則本身確有違法，依「不法不得主張平等」之法理，個案當事人始不能請求行政機關依循前違法行政規則加以辦理⁸¹。

二、公權利受侵害

國家變動既存法秩序之高權措施，例如行政機關侵益處分的作成、行政契約的不利變更或終止、侵益行政計畫的作成、或者立法者不利新法的訂定，由於其侵犯人民之既得權益，自有導入憲法基本權保障理念思維之必要。從而在此設定「公權利受侵害」要件的用意，除了具體呈現出國家對法秩序為不利人民之變更外，亦為下述法律保留原則、比例原則與損失填補提供了檢視之對象。

(一) 具體行政行為之作成

信賴保護原則旨在處理法秩序之不利變更，屬於憲法基本權保障之課題，則因國家變動法秩序而侵害公權利之具體措施中，計有行政處分、行政契約、與行政計畫等三種，以下筆者即依各種行為型式分別論述之。

1. 侵益處分之作成（含授益處分的廢棄）

所謂侵益處分（負擔處分），係指對人民產生義務課予或權利限制等法效果之高權決定，舉凡課稅、徵兵、基於行政管制或行政裁罰所為之不利行政處分，皆為侵益處分之適例。除上之外，使原

⁸⁰ 不同見解：學者陳新民認為，針對同一類型事實，平等原則所關注者係「同一時期」適用法律之對象；新法對「不同時期」所課予之不同法律效果，儘管屬完全同質之事務，亦非平等權之拘束範圍，請見陳新民（註1），頁184。

⁸¹ Maurer (Fn. 16), § 79 Rn. 127; Wolff/Bachof/Stober/Kluth (Fn. 47), § 24 Rn. 27.

授益處分法效性歸於消滅之「廢棄處分」，不論是違法處分的撤銷（Rücknahme）或合法處分之廢止（Wiederruf），因其共同特徵皆使受益人的公權利為之喪失，故其本質亦為「侵益處分」之一種⁸²，自應納入憲法基本權保障之考量，以限制行政機關在此廢棄權限的行使。不同於此，針對負擔處分之撤銷廢止，因該廢棄行為本質上對人民有利，並不構成公權利之侵害，因而行政程序法對該廢棄權限之發動便顯得寬鬆許多。

由上開說明可知，因侵益處分（含授益處分之廢棄）可能構成人民公權利之侵害，因而真正有信賴保護原則（憲法基本權保障）之適用者，應以「侵益處分」為是⁸³。復以，因憲法基本權保障使得行政機關對授益處分廢棄權限之行使受到限制，從而本文認為「對原處分之廢棄有無構成相對人公權利之侵害」的思維掌握，或可避免學界「適用授益或負擔處分廢棄之法理」此等過於轉折、繁複之表述方式，用以促進法學論理的明確與直接。

2. 行政契約之不利變更或終止

行政機關與人民間經共同磋商、意思合致而締結行政契約後，基於行政機關仍負有因應時勢與不斷形成公益之任務需求，為避免行政機關須受限於原先契約內容致有違公益，從而行政契約法制賦予行政機關得透過補償締約人民之損失，而享有單方變更、終止契約之法定權限（行政程序法第146條、第147條第2項）⁸⁴。是以行政契約締結後公權力主體如因公益而變更原契約內容致締約人民受有權益損失者，自應視為對人民公權利之侵害，而有接受法治國家合憲審查之必要。

82 BVerwG, DÖV 1957, 753 (754)；蕭文生，授益行政處分之廢止，台灣法學雜誌，151期，頁106（2010年）。

83 正確之見解：「廢棄行政處分時，……所應據以判斷者，並非原行政處分之為授益或加負擔，而係變更後之效果為授益或加負擔。」陳敏（註1），頁452。

84 陳敏（註1），頁606-610；林明鏘（註62），頁592-593。

3. 侵益行政計畫之作成（含授益行政計畫的廢棄變更）

行政機關為一定目的之達成，以現有事實為基礎而對未來預測之行政計畫，其類型不論是侵益行政計畫之作成，或者是行政機關嗣後對原授益行政計畫加以廢棄或作成不利變更者，二種情形皆有可能對人民在法律狀態上造成之不利影響。針對前者，例如新發布之都市計畫實施土地使用分區管制，致計畫範圍內不合土地使用分區規定之地上原有建物，受到不許增建與改建之限制（都市計畫法第41條），而使所有權人支配其財產之使用及處分權能受到減損。另就後者而言，司法院釋字第156號解釋指出：「主管機關變更都市計畫，係公法上之單方行政行為，如直接限制一定區域內人民之權利、利益或增加其負擔，即具有行政處分之性質……。」即屬此種情形之適例。

（二）不利新法之訂定（含授益法規的廢棄變更）

國家權力機關就一般事項而對外發布之抽象法規範（含法律、法規命令），倘該新規定之制定或對舊法之修正廢止，其效果對人民產生不利之影響（例如：對既有權利之剝奪、內涵減縮，或增加權利行使之限制），則針對此新規定所形成的法秩序，即構成對人民公權利之侵害，自有接受法治國家合憲性檢驗之必要。而肯認「不利新法之訂定」（含授益法規的廢棄變更）作為合憲審查之對象，在公法學的意義上，除了呼應「任何法律或法規命令皆不能預期其永久實施」之意旨外；另一方面，亦為「有利人民可以溯及」之主張找到了適切的論理支持，理由在於有利人民之溯及新法因未構成公權利之侵犯，自非憲法基本權防禦功能之指涉對象，從而毋須開啟基本權受侵害之流程審查⁸⁵。

舊法既已形成之法秩序，如因新法的訂定使人民權益蒙受不

85 Möller/Rüßmair (Fn. 2), S. 911.

利，特別在新法具有「溯及效力」(Rückwirkung)時，即有另為討論之必要⁸⁶。對此，德國法院實務就此議題之處理，依觀察角度之不同，而產生以下相異之類型區分。首先，德國聯邦憲法法院第一庭依「法律所規範者是否為已終結的事實」之立場出發，採取了「真正溯及」(echte Rückwirkung)與「不真正溯及」(unechte Rückwirkung)等區隔⁸⁷。其次，德國聯邦憲法法院第二庭則以「法律之生效時點是否早於法律之公布」為置準，發展出「法律效果的溯及生效」(Rückbewirkung von Rechtsfolgen)與「法律事實的回溯連結」(tatbestandliche Rückanknüpfung)二種概念對比⁸⁸。而在合憲審查的評價上，前者(真正溯及、法律效果的溯及生效)原則禁止，例外容許；後者則反之⁸⁹。

本文認為法規溯及效力之認定，首應予說明者係，如果未涉及新舊法變更，縱該條文內容使用「溯及」二字(例如行政程序法第118條、第125條但書)，亦與此處法規之真正溯及、法律效果之溯及生效無涉，如此方符本要件「公權利受侵害」(不利新法之訂定)的設定。其次鑑於事實本身並無終結之問題，唯有法律關係方

86 對溯及效力採「最廣義」標準，認為所有不利新法皆應摻入溯及作用者：陳雍之，法律之溯及效力——從德國判例及學說論法律變更時人民權益之保護，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁299以下(1991年)。依此，不利新法有無溯及既往，似無再為區分之必要。

87 採此見解：BVerfGE 13, 261 (271f.); 45, 142 (173 f.); 72, 175 (196); 101, 239 (263); 司法院釋字第580號許玉秀大法官一部協同暨一部不同意見書；陳新民(註1)，頁186以下；陳愛娥(註1)，頁188以下；林三欽(註75)，頁310-312。

88 採此見解：BVerfGE 72, 200 (241 f.); 97, 67 (78 f.); 105, 17 (37); Vogel (Fn. 1), S. 838; Maurer (Fn. 4), § 17 Rn. 108; 李建良(註1)，頁82；司法院釋字第605號楊仁壽、王和雄大法官部分不同意見書；林昱梅(註1)，頁17。
認為第二庭的新取向只是名稱更換而已，其內容、適用結果與第一庭並無二致者，請見：Pieroth (Fn. 3), S. 281; Möller/Rüßmair (Fn. 2), S. 908 f.; Christoph Brüning, Die Rückwirkung von Legislativakten, NJW 1998, S. 1525 (1526); Dirk Ehlers, Rechtsquellen und Rechtsnormen der Verwaltung, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl., 2010, § 2 Rn. 91; Jarass/Pieroth (Fn. 13), S. 504-506.

89 BVerfGE 13, 261 (271 f.); 72, 200 (257 ff.).

有終結之可能，是以為避免誤解，宜將德國聯邦憲法法院第一庭之用語，修正為「新法所規範者是否為已終結的法律關係」。承此，不利新法有無溯及效力，其觀察應非單就事實本身之發展即可，而是必須著眼於「規範事實」與「（舊法）法律要件」兩者間之全然合致始能得知，屬於法適用之層次；從而對真正溯及法規應予非難之處，在於其規範效力可突破個案的終結性，使舊法下已決之法律關係亦受到後來新法的重新評價，使受規範者（人民）之權益更受其害⁹⁰。反之，不利新法尚未觸及已終結之法律關係，即便其生效時點早於公布之日，在法治國中亦無加以禁止或推定違憲之必要；例如司法院釋字第589號解釋中，刪除政務人員享有月退職酬勞金而改以一次發給為限之「政務人員退職撫卹條例」（2004.1.7），該法雖溯自同年月一日施行，惟第三屆監察委員領取退職金之法律關係依舊法尚未終結，故其權益並未因不利新法之提前生效而更受不利，從而解釋文中並未論及法律不溯及既往原則，反而係以「比例原則」為由加以指摘之。承此，關於法規變更中不利新法的溯及既往，自應以德國聯邦憲法法院第一庭為是，以「新法所規範者是否為已終結的法律關係」加以論斷之。

1.（真正）溯及新法

立法者在制定、修正或廢止法律時，除了本身之公益追求外，基於法治國家中之法安定性與信賴保護原則，亦應兼顧既存法秩序之安定與人民所投以之信賴，此即不許新法為效力回溯之「法律不溯既往原則」⁹¹。不同於此，有學者鑑於立法上之法律不溯及既往並非我國憲法所明文規定之一般原則，且綜觀司法院歷來之釋憲實

⁹⁰ 之所以認定「法規範之溯及效力」，在於其將導致「法規範的溯及適用」。對此二者之精闢分析，請見彭鳳至，法律不溯既往原則之憲法地位，台灣本土法學雜誌，48期，頁10（2003年）；司法院釋字第620、714號解釋理由書。

⁹¹ BVerfGE 13, 261 (271); 45, 142 (167 f.); 72, 200 (242); 83, 89 (109 f.); 94, 241 (258); 97, 67 (79); Brünig (Fn. 88), S. 1527 f.; 陳新民（註1），頁171。

務，無一解釋係單純以法律不溯及既往原則為由，來推導出釋憲結果之合憲與否；甚且此原則所要表彰之「既得權保障」，也只是法治國家理念中的一環，非處絕對之地位，因而判斷新法妥當與否之審查基準，並不在於法規有無溯及效力之認定，而是取決於憲法整體價值之權衡。故就現階段以言，法律不溯及既往原則（既得權保障）尚不足以作為拘束立法者之憲法原則⁹²。對此學說爭議，本文認為不許新法為效力回溯之「法律不溯及既往原則」，其內涵並非旨在維護舊法秩序的持續安定或人民對舊法所投以之內心主觀信賴，而係防範新法的溯及規範效力對人民權益構成重大侵犯。亦即不利新法的溯及既往，其藉由法規（大前提）的抽換而變更已終結之法律關係，不僅導致人民對法規喪失預見可能性，同時亦使既定之權利義務須面臨一全新法規的突襲與不利對待（例如：行為後之溯及新法，將原本的個人行動自由惡化為應受處罰之犯罪行為），如此對人民既得權利的侵犯顯然失之過苛，而與「憲法基本權保障」之價值理念背道而馳。承此以言，為防範立法者恣意變更已終結法律關係之「法律不溯及既往原則」，實為依憲法基本權保障所推導而出之「憲法原則」⁹³。

而在「公權利之侵害」之要件審查中，除了特定法領域（刑法、行政罰法）外，不利人民之新法倘得出具有溯及效力之認定，此際並非已然違憲，而是存有高度的違憲疑慮而已⁹⁴。亦即此等立法決定倘出於手段必要性與明顯重大公益之考量，仍得在比例原則之審查中，以此阻卻違憲結論的產生。而由此利益權衡、取捨之過程，亦突顯出具有憲法位階之法律不溯及既往原則，並非作為實證法意義下的法規則，而係代表特定價值取向的「法原則」（*Rechtsprinzip*）。

92 彭鳳至（註90），頁4-12。

93 另請參見：*Möller/Rührmair* (Fn. 2), S. 909 f.；陳愛娥（註2），頁142。

94 BVerfGE 2, 380 (405)；李建良（註1），頁85。

2. 不真正溯及新法

不真正溯及新法意謂法規係以未終結之法律關係作為規範對象，使當事人之既得權利或法律地位接續產生不利影響者而言⁹⁵。相較於溯及新法，不真正溯及新法對未終結法律關係之規範，毋寧係一般法規生效之常態，屬於「立法行為侵害基本權利之原型」⁹⁶，從而長期以來關於基本權受侵害之合憲性審查，其對象亦以此類法規為大宗。承此以言，我們實不必對不真正溯及新法作特殊意涵之解讀，一言以蔽之，其不過就是「不具溯及效力之不利新法」而已⁹⁷。

關於抽象法規不利變更之處理，由於本文採取了德國聯邦憲法法院第一庭以「新法所規範者是否為已終結的法律關係」作為判別標準，進而產生「真正溯及新法」與「不真正溯及新法」之概念二分。在此置準之下，倘不利新法之規範對象未涉及已終結之法律關係，則無論其與舊法所規範的事實如何之緊密相連（具有連續性），或新法的規範內容對人民權利產生何等之重大影響，皆不改系爭不利新法屬於「不真正溯及新法」之認定。

除此之外，本文認為學說關於不真正溯及新法「原則許可，例外禁止」之規範描述，實相對於（真正）溯及新法之違憲推定而存在，其本身並不具有獨立之意涵。亦即不真正溯及新法在評價上究屬合憲與否，並非「原則一例外」所能回答，而是必須經由比例原則中各派生原則的逐一檢視，始能知之。循此以言，本文建議關於不利新法本身合憲與否的判斷，或許可以考慮放棄「原則一例外」

⁹⁵ 彭鳳至（註90），頁6。

⁹⁶ 依學者觀察指出，德國聯邦憲法法院第一庭關於不真正溯及新法之處理，亦有回歸「基本權侵害」論述之態勢。請見 *Vogel* (Fn. 1), S. 837.

⁹⁷ 司法院釋字第574號許玉秀大法官部分協同意見書、司法院釋字第605號曾有田大法官協同意見書皆指出「不真正溯及既往」或「法律事實之回溯連結」等概念之使用，似屬多餘。本文認為此等見解實屬正確，亦具參考之價值。

的語彙使用，而直接以「（真正）溯及新法因牴觸法律不溯及既往原則而受違憲推定；不真正溯及新法須視對人民權利影響之程度，而受比例原則寬嚴不等之檢驗」作為表述方式，以避免產生認知上——訂定不真正溯及新法「原則皆為許可」之誤導。

三、法律保留原則

通說有關信賴保護議題之思考，係以信賴基礎、信賴表現與信賴值得保護等要件加以檢視，並輔以法律效果之公私益衡量作為保護方式。相形之下，「法律保留原則」之操作於此就顯得較為陌生。惟考量信賴保護之課題，旨在處理國家能否對既存法秩序而為不利變更，屬於憲法基本權利之防禦功能面向，從而謹守法律保留原則之固有意涵——「侵害保留」（Eingriffsvorbehalt）之意旨⁹⁸，國家行為倘侵害人民之自由權利，自應取得法律或法規命令之形式授權，以符憲法保障基本權利之價值決定。

關於行政機關就違法處分之職權撤銷部分，學者翁前院長岳生曾撰文指出，由於違法處分本身即構成依法行政原則之背離，對之撤銷乃行政機關應盡之義務，因而倘以未有法律依據為由而限制行政機關撤銷權之行使，不啻形同聽任違法狀態之繼續存在，自非允當⁹⁹。對此本文認為，在行政程序法尚未立法通過前，倘嚴格貫徹法律保留原則，勢因法律規定之欠缺而導出「違法授益處分一概不許撤銷」之結論，如此顯有偏重人民權利保護，卻忽視法治國家中回復合法狀態之公益需求的謬誤；從而學者主張行政機關職權撤銷違法授益處分毋須法律保留原則之見解，實為因應當時法制不備下之折衷辦法，自有其時代意義而應予肯定。惟鑑於授益處分之撤

⁹⁸ Jarass/Pieroth (Fn. 13), S. 496 f.; 許宗力，基本權（上）（註45），頁72以下；黃舒芃，法律保留原則在德國法秩序下的意涵與特徵，中原財經法學，13期，頁7以下（2004年）。

⁹⁹ 翁岳生，行政處分之撤銷，收於：法治國家之行政法與司法，2版，頁44（2009年）；許宗力（註31），頁542；陳淳文（註16），頁35。

銷，本質為「侵益處分」之一種，理應有法律或法律授權之命令作為依據，始得為之¹⁰⁰。是以在行政程序法公布施行後，不論是違法授益處分之撤銷（行政程序法第117條）、或合法授益處分之廢止（行政程序法第123條），行政機關皆已取得相關措施的行為法授權，而與積極之依法行政原則——法律保留原則，無所牴觸。

而行政契約締結後，公權力主體為維護公益而單方調整契約內容，致相對人履約時顯增費用或受其他不可預期之財產上損失時，此等行政機關公權力行使所造成之人民權益侵犯，已有行政程序法第146、147條作為其授權規定。此外在有利人民之行政計畫中，倘於計畫實現過程中遇有特殊原因，而須對原先計畫加以終止或作不利人民之變更，自應於系爭計畫賴以作成之相關規定中，尋繹出採行此等侵益措施之法規範依據（例如：都市計畫法第27條、區域計畫法第13條、行政程序法第117、123條）。

至於抽象法規的制定、修正或廢止，倘系爭不利新法具有溯及效力，或其內容將構成人民權利之過度侵犯者，則在整個規範層級中，自應以「法律」之型態出現，方無違法律保留原則之要求。除上述事項之外，立法者在合乎「授權明確性」之前提下，自得將本身之規範制定權限委由行政機關以法規命令之方式訂定之，而同樣達到限制人民權利以實現公益之規範效果。又因立法者之「制定授權」中，通常及於對法規命令之變更（Änderung）與廢棄（Aufhebung）在內¹⁰¹；從而行政機關嗣後對法規命令的變更、廢棄，縱對人民產生不利之影響，亦不以取得立法者再次之授權為必要。

¹⁰⁰ 蕭文生（註82），頁106。

¹⁰¹ *Wolff/Bachoff/Stober/Kluth* (Fn. 47), § 25 Rn. 45.

四、比例原則

(一) 概論

當代國家雖有因應時勢變遷而不斷形成決策之公益需求，惟在與時俱進的同時，若有侵害人民既得權利之虞者，自涉及憲法基本權防禦功能之領域範疇。而在基本權審查中設立比例原則之用意，即旨在透過「目的」與「手段」間之關連性，來規範國家公權力行使之限度，以防止人民之自由權利受到不合比例之侵犯¹⁰²。詳言之，除了限制基本權之目的須為實質正當（目的正當性）外，國家為達成公益目的所採取之手段（手段適合性），亦應是眾多方法中侵害最小者（手段必要性）、且人民權益侵害與公益目的達成間不得利益失衡（法益均衡性）¹⁰³。唯有合於上述各項基準之逐一檢驗，始能正當化國家在此侵益措施的採行。

而在通說有關信賴保護之流程處理中，「公益與私益之衡量」並非信賴保護之成立要件，毋寧是法律效果中國家選擇保護方式（存續保護、財產保護）之判斷準據¹⁰⁴。相異於前，類如授益處分之撤銷、不利新法之訂定，國家於此對公權利限制之目的是否實質正當、手段能否有助於目的之達成、有無逾越必要之限度或符合法益間之均衡，此等比例原則之定位係作為本文階層審查架構的要件之一。換言之，個案情形經由比例原則檢視後，倘得出國家應使人民既得權益維持存續之結論，其緣由即非來自於國家「選擇」存續

¹⁰² 李建良（註17），頁91。

¹⁰³ *Pieroth/Schlink* (Fn. 14), S. 64; *Maurer* (Fn. 4), S. 224 ff.; *Jarass/Pieroth* (Fn. 13), S. 509 ff.; 司法院釋字第476號解釋；許宗力，基本權（下）（註45），頁50以下。

¹⁰⁴ *Maurer* (Fn. 16), § 79 Rn. 94; *Püttner* (Fn. 4), S. 217 f.; 林錫堯（註1），頁75；洪家殷（註22），頁52-53；林明鏘（註28），頁593；林三欽（註24），頁36；蔡宗珍（註38），頁89；李震山，行政損失補償請求權——以行政程序法之補償規定為例，收於：多元、寬容與人權保障——以憲法未列舉權之保障為中心，頁356以下（2005年）。

保護之結果，而是意謂著國家所擬採行之高權侵益措施，在此通不過比例原則之審查所致。

（二）具體侵益措施的採行

德國在二戰前因強調國家高權的鞏固與公共利益的優越，從而對違法授益處分之態度係採取「自由撤銷原則」；惟此見解走到1950年代中期以後，德國行政法院另發展出所謂的信賴保護原則，以之限制行政機關處分撤銷權限的行使，用以保障處分相對人之既得權益¹⁰⁵。依此，在違法授益處分撤銷之場合，便涉及「公益原則」與「憲法基本權保障」兩者間之價值取捨。而在具體個案的處理中，關於「撤銷所欲維護之公益」部分，應將授益處分違法瑕疵之嚴重性、撤銷與否對公益之影響（含第三人之利害關係）等因素一併列入考慮¹⁰⁶；而於「人民私益」部分，毋須探究相對人內心是否知悉處分之存在、作成處分之官署層級、與程序踐履是否嚴謹，惟應斟酌處分涉及之權利種類、該權利是否為惡意取得、處分相對人有無對外具體表現、以及撤銷所致之權益侵害能否另以相關措施填補之。在此情形下之利益權衡，立法者規定必須是私益「顯然」大於撤銷所欲維護之公益（行政程序法第117條但書第2款），方得不為違法授益處分之撤銷。

可供討論者是，德國聯邦行政程序法第48條第2項針對「金錢或可分物給付之授益處分」中，倘受益人具有值得保護之信賴，則相較於「其他種類之授益處分」，因該類財產給付僅涉及國庫利益（fiskalischen Interessen）、或受益人可能已消費耗盡或作出重大之財產處置或對此產生經濟上之高度依賴，從而應給予較高度之存續保

¹⁰⁵ Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 28), § 48 Rn. 135 ff.; Maurer (Fn. 16), § 79 Rn. 93; Schmidt (Fn. 2), S. 534; Matthias Ruffert, Rücknahme von Verwaltungsakten, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl., 2010, § 24 Rn. 19.

¹⁰⁶ Maurer (Fn. 1), § 11 Rn. 33.

障¹⁰⁷。否定見解則認為，此等立法例「易導致受益人之財產利益必然大於公益之不當結論」，而扭曲比例原則中的法益權衡原則¹⁰⁸；且過度強調信賴保護，其結果將是國庫為所有違法瑕疵行為買單、公益為私益而犧牲¹⁰⁹；又上述就處分內容而異其處理之規定，實為徒增複雜之設計，故此區分殊非必要¹¹⁰。對此本文亦認為，違法授益處分內容如涉及財產給付，行政機關得透過「撤銷但不溯及既往」、或「撤銷另給予補償」來減輕相對人所受之財產損失；甚且更重要者係，該處分如具有持續之效力（如按月核發社會救助金），不予撤銷除了使處分之違法狀態持續下去，同時易生於法不合的過度給付，而造成國家有限資源的排擠與浪費。綜上所言，上述學說爭議自應以否定見解較為可採。

有別於違法授益處分的撤銷帶有合法性回復之公益需求，合法授益處分之作成因具有落實法規意旨之功能，且其存續亦符合人民既得權利之維護，是以關於合法授益處分之廢止，其發動必須具備「法定廢止事由」，原處分機關始得為之。而於各款法定廢止事由之比例原則操作，原處分機關自應具體表明公益之內涵，不得僅以空泛公益之名為之，始能判斷其廢止權限之行使是否有違法裁量等情事¹¹¹。而在方法手段的採行上，廢止機關應視具體情形就原合法授益處分為全部或一部之廢止，或在時間上選擇原處分自廢止時或另行指定較後之日起，失其效力（行政程序法第125條本文）。

在合法授益處分之「法定廢止事由」（行政程序法第123條）中，如個別法規准許行政機關廢止授益處分者，則如學者正確指

107 *Wolff/Bachof/Stober/Kluth* (Fn. 47), § 51 Rn. 93; *Kopp/Ramsauer* (Fn. 53), § 48 Rn. 84; *Stelkens/Bonk/Sachs* (Fn. 28), § 48 Rn. 139; *Meyer* (Fn. 1), § 48 Rn. 86; 林三欽（註24），頁32-36；董保城（註31），頁482。

108 洪家殷（註22），頁53，註腳53。

109 陳淳文（註16），頁43。

110 吳庚（註22），頁389-390。

111 董保城（註31），頁476。

出：因其使處分相對人蒙受不利，自應顧及人民權利保障給予適當補償，倘允許廢止授益處分之法律未同時設有補償規定，該法律即整體違憲¹¹²；蓋本諸憲法基本權保障之考量，國家廢止授益處分致生人民權利之過度侵犯，縱有個別法規之授權，亦不足以免除國家本應擔負之損失填補義務。其次，處分機關為原處分廢止權保留者，其不僅須與該處分之目的具有正當合理之關聯（行政程序法第94條），且應具體詳載廢止權發動之原因，以避免處分機關動輒為此附款之添加並嗣後任意廢止之¹¹³。再者，受益人未履行負擔者，由於受益人本身具有可歸責事由，自應減免其權利保護，因而此該合法授益處分之廢止，得溯及既往失其效力（同法第125條但書）。又合法授益處分作成後倘發生情事變更，行政機關得為避免公益發生危害而為處分之廢止；惟應予留意者係，此廢止權之發動仍應遵循「法益均衡性」之要求——即所造成之人民權益損失不得與欲達成之公益目的間顯失均衡¹¹⁴。最後，除上述各類法定廢止事由外，行政程序法第123條第5款係作為行政機關對合法處分廢止權行使之補遺規定，用以防止或除去對公益之重大危害。

而行政程序法第146條第1項規定公行政主體在行政契約締結後，得單方對契約內容為不利變更或終止，有學者對此條文中何謂「於必要範圍內」、「有公共利益之重大危害」等文字提出質疑，認為「此需學界提供具體化之界限，否則將可能有濫用公權力之危機出現¹¹⁵。」不過既然行政契約法制在履約階段係以「公益優先」為指導原則、當事人間上下隸屬關係為預設¹¹⁶，是以該條項之規定應

112 許宗力（註31），頁530。不同見解：認為本款不生信賴保護且毋庸補償，乃因「相對人有所預見之緣故」，請見吳庚（註22），頁395；董保城（註31），頁484。

113 *Wolff/Bachof/Stober/Kluth* (Fn. 47), § 51 Rn. 33.

114 陳敏（註1），頁472。

115 林明鏘（註62），頁592。

116 林明鏘（註62），頁586。

為立法者就比例原則中「手段必要性」與「法益均衡性」等理念之具體展現；亦即在賦予行政機關享有優勢地位與權限之餘，另搭配比例原則作為配套，以資兼顧人民在契約關係中之權利保護。

至於國家以一定地區土地之特定利用或設置重大公共設施之計畫行為，倘其涉及人民之權利義務（例如：垃圾掩埋場的設立將影響農作物的收成品質、重工業廠房的進駐將造成身心健康的戕害），除了依法應落實相關民主參與程序外（行政程序法第164條第1項：「應經公開及聽證程序」），亦應由比例原則的介入檢視：課予計畫機關採行必要之防護措施、或否定整個計畫決定的作成，以維護當地居民之健康與環境權益¹¹⁷。此外在計畫確定之後，如遇有相關情事變更（例如：在道路開發計畫區域內發現史前人類遺址或極為珍稀之濕地生態），即便原先計畫對人民較為有利，亦應肯認行政機關對該計畫內容之調整與廢止權限，以免公共利益受到難以回復之重大危害。

（三）抽象法規的不利變更

法規訂定機關制頒新法或對舊法加以修正、廢止，此等法秩序變動如構成人民自由或權利之侵害，依憲法基本權保障之價值理念，其必須出於維護公益所必要（憲法第23條），且係社會整體利益優先於舊法受規範對象之個別利益，法規訂定機關始得依法定程序廢止法規或修改其內容（司法院釋字第525號解釋理由書參照）。而關於個案之法益權衡，於公益之部分須就建立合理制度之抽象價值、增進國民福祉之具體利益、所涉人數之範圍多寡、以及國家財政負擔能力加以斟酌（司法院釋字第589號解釋參照）；於人民私益則應就權利之種類（如實體權利、程序利益；生命權、身體權或財產權）、與權利受侵犯之程度等因素綜合考量之¹¹⁸。

117 董保城（註64），頁602以下。

118 許宗力，基本權（下）（註45），頁54-57。

可資贊同者係，司法院釋字第589號解釋文指出，舊法之作用如在保障私人法律地位之外，亦具有藉該法律地位之保障以實現公益目的者，則關於此一法律地位之保護即應予強化以避免受害，俾使舊法所欲實現之公益目的亦獲得確保。從而該號解釋之聲請事實中，立法者出於改革政務人員退職制度之政策目的，而就監察委員之退職給與，由擇領月退職酬勞金改以「一次發給」為限，此不利新法因未就依法獨立行使職權而賦予任期保障之憲法意旨列入考慮，致影響監察委員職務功能之發揮而有礙公益，而於比例原則中牴觸了法益均衡性之要求¹¹⁹。

如前所述，相較於「不真正溯及新法」須視對人民權利影響之程度而受比例原則寬嚴不等之檢驗；牴觸法律不溯及既往原則之「（真正）溯及新法」，因其規範方式易造成人民權益過度侵犯而受到違憲之推定，從而在比例原則中自應接受嚴格標準之審查。例如罪刑法定原則下所派生之「溯及處罰禁止原則」，無論國家在此係出於何等急迫與重大之公益考量，皆不許法律於行為後回溯處罰或加重處罰，以避免行為人遭受國家刑罰權之恣意侵害，此乃近代法治國家建構刑法學的基本原則¹²⁰。此外針對違反行政法上義務所科以罰鍰、沒入或其他種類之行政罰，此等處罰效果雖不似刑罰嚴厲，惟其本質上仍屬對於人民自由或權利之不利處分，是以關於行政罰之裁處，亦應以「行為時」之法律或自治條例有明文規定者為限¹²¹，而禁止立法者事後以公益之名，訂定具行政裁罰效果之溯及性法律，以符憲法基本權保障之價值理念。

119 對本號解釋之質疑：吳庚（註22），頁67。

120 司法院釋字第271號吳庚大法官不同意見書；陳新民（註1），頁152以下；李建良（註1），頁85；司法院釋字第714號羅昌發大法官協同意見書。

121 立法院公報，94卷6期，頁356（2005年）。

五、損失填補

(一) 概論

國家因公益而變動既存法秩序之侵益行為，倘其合於前述法律保留原則與比例原則之檢驗，在法治國的評價向來以「合法」或「合憲」稱之。然而針對此一國家最小侵害手段所造成之人民權益損失，此該不利益是否為人民所應忍受，或者說國家有無另為損失補償或採行相關措施以資緩和之義務，除了財產權的公益犧牲外，此該問題向為傳統基本權受干預之合憲審查所忽略。而信賴保護原則揭示受益處分廢棄後之財產保護、以及法規不利變更有關補救措施或過渡期間條款之訂定，則不僅適度填補此等思維的空白，並兼顧人民權利受侵害後的保護需求，本文認為此乃學說發展信賴保護原則之最大貢獻所在。

在多元利益交織的現代社會，由人民代表所組成之國會，為追求全體國民的共同福祉或促成人際間自我的最大實現，自得以「法律」（含法規命令）限制人民之自由權利（憲法第23條），此等以抽象、一般之形式出現，而為全體社會構成員所共同遵守之規範，即為近代權利社會化下的必然結果，又稱為權利之「社會義務」。例如立法院修法提高稅率或新增稅目，由於稅捐繳納係人民應盡之社會義務（憲法第19條），原則無訂定補償措施之必要。相異於前，如法律之限制已逾越人民權利社會義務之範疇，自應有相關補償或緩和措施以為配套，始得為之；在此人民權利遭受之過度侵犯，倘非金錢或其他措施所能彌補、平復，基於個人權利不應為公益而作平白犧牲，本諸憲法基本權保障之意旨，將使國家變動既存法秩序的採行喪失正當性而受到禁止¹²²。

¹²² 應予說明者係，旨在處罰人民之「刑事法規」與「行政罰法」，因該處罰手段係針對行為人違法行為的制裁，且基於處罰目的之達成，亦應理解為行為人

由上可知，損失填補義務的發生係因權利社會義務之逾越，因而社會義務與國家過度侵犯之間，本文認為宜回歸權利之概念並結合其受干預之強度，以「法益減損說」來作為劃分兩者之具體判準¹²³。按權利者，係依法受保護之特定利益（法益），是以國家干預強度如造成人民法益之喪失（例如土地徵收）或減損（例如經指定為古蹟或公共設施保留地，致財產權之使用收益權能幾近喪失），此即應予填補之權利過度侵犯。反之，高權干預內容如僅侷限特定之時間、方式、場合或地域，而對權利未構成持續或全面之限制¹²⁴（例如道路交通管理處罰條例第31條之1禁止行車時使用手持行動電話、或刑法對特定犯罪行為之禁止），因其未造成法益之減損，此即權利主體所應容忍之社會義務。至於國家對偽鈔之沒收（刑法第205條）、或違章建物之下命拆除（建築法第86條），由於現行法中偽鈔、違建皆非受保護之「法益」，是以國家縱對此不法利益加以剝奪，亦不生損失填補之問題¹²⁵。

本文認為，在基本權（自由權）受干預之審查流程中增設損失填補之要件，可以統合法秩序不利人民變更之信賴保護原則、財產權之公益犧牲、以及非財產權之犧牲請求權（Aufopferungsanspruch）等概念。蓋上述三者之發生皆因國家高權措施過度侵犯人民權利所致，屬於憲法基本權利保障之課題；並且其共同特徵：因「公益」而受有侵害，則已為審查流程中之「比例原則」所涵括，亦即在要件審查順序上，必以系爭高權侵益措施先合乎比例原則——係出於公益，且為公益大於私益之侵害手段，方有再進入討

所應容忍之社會義務，而無另訂權利補救措施之必要。

123 國家侵犯是否過度（或謂「特別犧牲」），德國學界曾發展出個別處分理論、值得保護理論、私用性理論、與可期待忍受理論等諸多判準，礙於篇幅，筆者在此僅提出個人見解，而不對上述學說加以介紹、檢討，讀者有興趣可自行參閱相關文獻。

124 另請參見：李建良，行政法上損失補償制度之基本體系，東吳法律學報，11卷2期，頁87（1999年）。

125 吳庚（註22），頁733。

論損失填補要件之可能。如此，公法學實毋須再因高權侵害方式與權利受侵害種類而給予不同的命名區分，而是只要國家措施構成權利過度侵犯，人民即享有相對應之「損失填補請求權」。

除上之外，藉由「損失填補」要件的觀察，亦有助於學說有關「基本權核心理論」之爭議解決。基本權核心理論強調國家公權力侵害不得觸及權利之核心領域（本質內涵），換言之，其課題亦屬基本權（自由權）之防禦面向；不過是否所有權利皆內含核心、以及如何認定其核心領域，實為該理論之難題所在¹²⁶。對此本文認為，任何造成人民權利過度侵犯又無從加以填補者，即為權利之核心領域所在。從而在憲法第16條訴訟權中，如果依法審判與法定法官原則可以因為公益而受到犧牲，則憲法對整個公平法院的建置，勢將形同破毀；同理，在當今的文明社會，死刑之所以存在著高度的違憲疑慮，是因為生命無可取代；再者，人性尊嚴神聖不可侵犯，是因為尊嚴乃是人存在之目的，而且是最終目的，對之侵犯無從以他種方式加以填補，以免人民淪為國家統治的客體、工具。與之相反者，在資本主義下之經濟結構，理論上一切有形及無形財產，皆可藉由金錢換算出一定價值（價值保障），正因為如此，在財產權的權利內涵中，向來未有一不容侵犯之核心領域存在。

（二）具體侵益措施的損失填補

人民之公權利倘來自於授益處分，其後行政機關對此授益處分之撤銷廢止，本質即構成相對人既存權利的完全剝奪，屬於權利之過度侵犯，在此首應判斷者，係「損失填補必要性」之問題。亦即在違法授益處分中，如為惡意取得權利、欠缺一定相關之對外具體表現；或於合法授益處分中未履行負擔者，此等情形皆因受益人具有可歸責事由或缺乏實際損失，國家即無對之填補的必要。

¹²⁶ 陳慈陽，基本權核心理論之實證化及其難題，2版，頁107以下（2007年）。

在釐清行政機關之填補義務後，其次則應思索「損失填補可能性」之問題。亦即原處分內容如涉及資格或身分之授予者（如外國人歸化許可、公務員之任命），由於此等處分之廢棄往往構成權利過度侵犯且難以補救，故應盡可能地維持此等受益處分之存續¹²⁷。相較於前，人民公權利如因受益處分之廢棄而受有財產上損失者，例如因辦理公用徵收而為土地財產權之廢止¹²⁸、撤銷營業許可（職業自由）所致之開業準備損失（如店面裝潢、廣告刊登）等，即得以金錢補償之。而除了金錢補償方式之外，如法律明定行政機關得另行指定處分失其效力之日期（行政程序法第118條但書、第125條本文）、或採行其他補救措施（例如文化資產保存法第35條第1項，因古蹟指定而享有建物容積移轉之優惠），則此亦不失為減輕受益人財產上損失之權宜作法。

而在金錢「補償額度」方面，合法受益處分之廢止，應依其損失給予受害人民「相當」之填補；違法受益處分的撤銷，其判準則在相對人對外具體表現所致之「實際損失」¹²⁹。而不論是處分之撤銷或廢止，兩者之補償額度，皆不得超過受益人因該處分存續可得利益之上限（行政程序法第120條第2項、第126條第2項），以避免給予相對人過多的價值保障，致金錢補償之範圍漫無邊際。

另於「行政契約」之部分，締約機關如為防免公益受到重大危害，而於必要範圍內調整、終止契約；或情事變更後為維護公益而命締約人民繼續履行原約定之義務，就相對人因公益所受之損失自應加以填補，我國行政程序法第146、147條對此皆訂有明文¹³⁰。至

127 Püttner (Fn. 4), S. 204; Kisker (Fn. 7), S. 187; 洪家殷（註22），頁52。

128 Maurer (Fn. 16), § 79 Rn. 106; Stelkens/Bonk/Sachs (Fn. 28), § 49 Rn. 124 ff.; Matthias Ruffert, Widerruf von Verwaltungsakten, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl., 2010, § 25 Rn. 19.

129 此處之「實際損失」，係指事實上損失（例如財產處置或生活計劃安排），而與授益處分撤銷所致之法律上損失（權利喪失）有異。

130 林明鏞（註62），頁592-594；李震山（註104），頁333-334。

於「行政計畫」中，計畫機關因公益之需要，而為侵益行政計畫的作成，如該不利狀態顯已逾越人民所應容忍之社會義務範圍而構成權利過度侵犯，自有採行損失填補之必要。例如為確保都市生活品質而於都市計畫地區範圍內指定公共設施保留地，此等限制如造成土地所有人財產使用收益權能的減損，自須給予相當程度之損失補償（司法院釋字第336號解釋理由書參照）。又情形倘為行政機關對授益行政計畫加以修正或廢棄，因而構成人民權益之過度侵犯，對此亦應負有損失填補之義務¹³¹。

（三）不利新法的損失填補

因公共利益之考量，立法者不利新法之制定倘對人民權利造成過度侵犯者，自有另為訂定補救措施或過渡期間條款之義務，以適度減輕法秩序變更所帶來之衝擊。由於上述緩和措施可能為受害人民創設一定之法律權能（如因土地徵收所生之損失填補請求權），或者決定不利新法之生效時點，因而關於補救措施或過渡條款的增訂，自宜以「法律」之規範形式為之。例如立法者在制定土地徵收法律時，亦負有一併訂定損失填補之義務，此等以法律結合徵收與補償之規定（唇齒條款），即為法治國中「有徵收必有補償」之原則體現¹³²。又例如司法院釋字第575號解釋中，原辦理戶政業務之警察人員因立法者為回復戶警分立制度而為機關組織之調整，致其服公職權利產生重大不利影響，內政部因而以「函」發布當事人得轉任為一般公務人員留任原職、或依其意願於五年內辦理回任警職之補救方案。惟此值得思考之處，係主管機關之函令本身無從作為賦予當事人權利之規範依據，已如前述；且系爭方案內容並非對相關人員單純授予利益，而係作為其權益受損之補救措施；甚而不利新法如對相關人員服公職權利產生重大影響，則此補救措施的採

¹³¹ Maurer (Fn. 1), § 16 Rn. 35; Ossenbühl (Fn. 64), S. 386; Schmidt (Fn. 2), S. 530.

¹³² 司法院釋字第400、409、516、652號解釋；司法院釋字第579號謝在全大法官協同意見書；葉百修，損失補償法，頁158以下（2011年）。

行，亦足以對其服公職權利產生重大影響，是以針對相關人員之權益補救方案，此等事項亦應以法律明確規定之，方符憲法第18條保障人民服公職權利與憲法第23條法律保留原則之理念意旨。

不利新法的立即上路倘造成人民因應不及致權益影響過鉅，立法者運用「**過渡期間條款**」來延遲不利新法之生效時點，此等設計雖不似補救措施能為受害人民另創設出可資主張之法律權能，惟其亦為減輕人民權益損失之常見作法。例如基於健全土地登記專業代理人制度之重要公益，而新增土地登記專業代理人應經考試或檢覈及格之主觀條件限制，此對修法前已實際從事土地登記代理業務而未取得相關資格證明者，新法則以為期五年之過渡期間條款作為執業年限，使當事人於此段期間內，得依其意願選擇是否參加考試、檢覈或改業，以資兼顧當事人受憲法所保障之工作權利¹³³。

值得一提者係，從司法院釋字第525號解釋作成以來，不利新法有無補救措施或過渡期間條款之增設，往往成為左右釋憲結果之論理依據。有別於此，司法院釋字第605號楊仁壽、王和雄大法官部分不同意見書則正確地指出，不利新法究屬合憲與否，其思考不能止步於不利新法存有「過渡期間條款」之訂定，而應進一步就過渡期間條款之內容予以實質審查¹³⁴。換言之，立法者就過渡期間條款之設置，其內容倘有恣意裁量或顯非合理之情形，而不足以緩和和人民所受之過度侵犯，將使不利新法面臨違憲的指摘。本文認為，為落實基本權利保障之憲法決定，楊、王兩位大法官之意見，亦可適用於「補救措施」的審查上。

六、小結

信賴保護原則的理論基礎因來自於「憲法基本權利保障」，從

¹³³ 司法院釋字第352號解釋參照；陳新民（註1），頁223。

¹³⁴ 司法院釋字第605號楊仁壽、王和雄大法官部分不同意見書第二點參照。

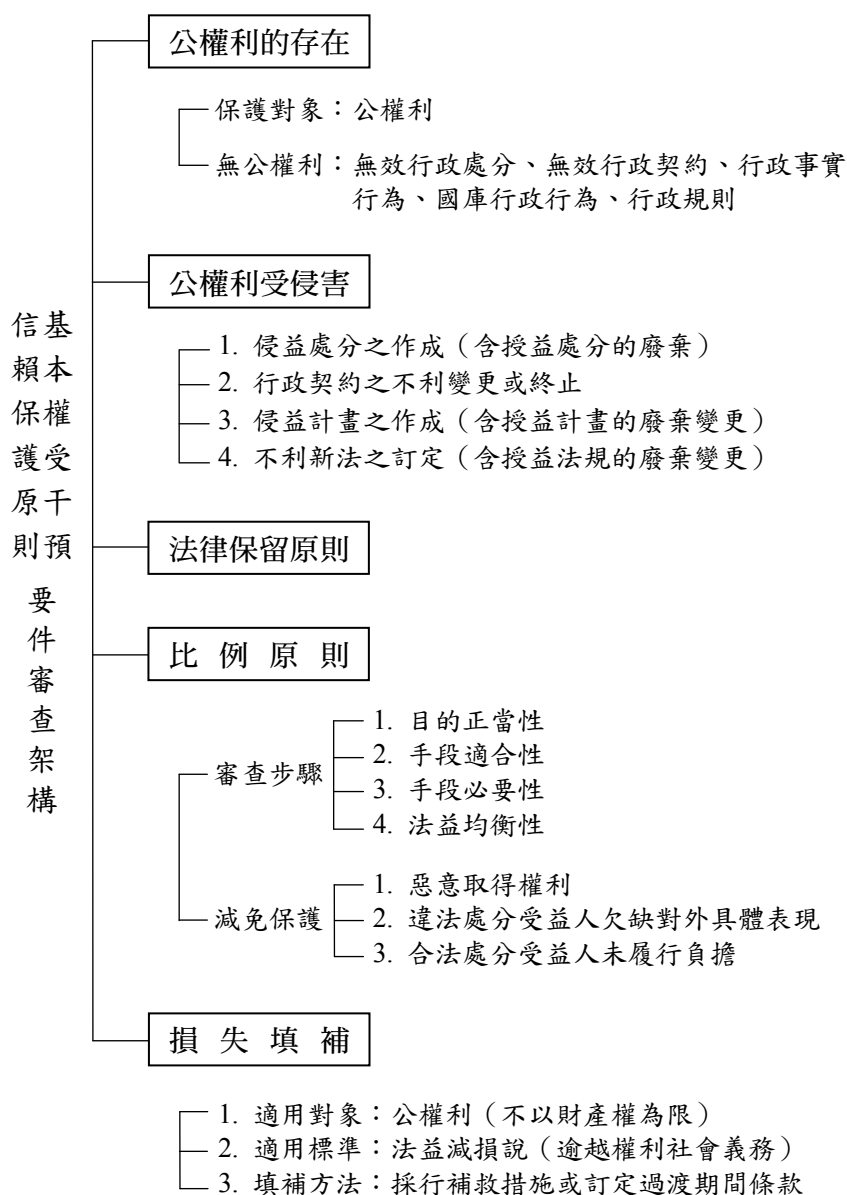
而探尋被保護之對象——「公權利」的存在，即成為處理系爭課題之首要。在此要件設定之下，無效的行政處分、無效的行政契約、行政事實行為、國庫行政行為、以及被定位為行政內規的行政規則，因此類國家行為皆無從為人民在法秩序中創設出公權利，自應排除於受保護對象之外。

其次，國家出於公益而變動既存法秩序，此等高權措施如造成人民公權利之侵害，包含侵益處分之作成（含授益處分的廢棄）、行政契約之不利變更或終止、侵益行政計畫之作成（含授益行政計畫的廢棄變更）、抑或是不利新法之訂定（含授益法規的廢棄變更），咸應合乎法律保留原則之規範要求，以及比例原則各項子原則的層層檢驗，始能初步正當化國家在此對公權利之侵犯。

即便該國家高權侵益措施取得法律之形式授權，且係影響人民公權利之最小侵害手段，倘其造成之權益損失已逾越人民所應容忍之社會義務範疇，而構成公權利之過度侵犯，自應有相關補救或緩和措施以為配套，以避免個人權利為公益而遭受平白犧牲。

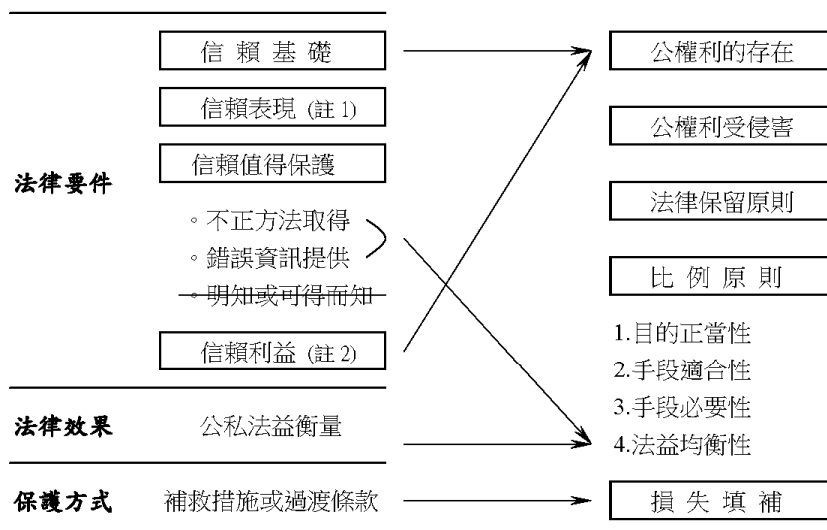
回顧上述所言，現行信賴保護原則要求國家變動法秩序應顧及人民之既得權利，其雖忽略對國家高權侵益措施之規範控制（法律保留原則、比例原則），惟其本質仍屬基本權（自由權）之防禦功能面向，而與憲法基本權受干預審查流程之議題重心無異；而信賴保護原則揭示國家應採行補救措施或訂定過渡期間條款之規範論述，則完備了既有憲法基本權受干預審查流程之思維體系。由此可知，信賴保護原則與憲法基本權受干預之審查流程間，並非兩套各自獨立的體系脈絡，而是對同一價值理念作不同的角度詮釋；唯有整合二者間之歧異，化對立為統一，方能使法治國「**憲法基本權利保障**」之實現，益臻完善。承此，茲將本文對信賴保護原則之審查架構，圖示如下：

圖2 信賴保護原則之（新）要件審查體系



資料來源：作者自製。

圖3 信賴保護原則之新舊要件審查體系對照表



(註1)：在右側新要件體系中，不以信賴表現為必要。惟於違法授益處分之場合，對外具體表現即為當事人所受之實際損失，於「法益均衡性」中加以審酌。

(註2)：「信賴利益」是否為信賴保護之審查要件，學說尚存爭議。

資料來源：作者自製。

伍、相關釋字簡評

信賴保護原則出現於我國釋憲實務，包含新法效力應否溯及既往之司法院釋字第410號解釋、行政規則有無信賴保護原則適用之司法院釋字第525號解釋、權利取得過程中法規廢止之司法院釋字第529號解釋、新法修正提高權利行使門檻之司法院釋字第574號解釋、以及訂定不利新法之司法院釋字第577號解釋，此五號釋字因涵括法規不利變更的可能型態，足堪為司法抽象審查中信賴保護原則之代表性釋字，亦為筆者印證信賴保護實為憲法基本權保護之案

例素材，而極具提出檢討之學術價值。至於其他相關司法釋字，或已為文中所闡釋（例如司法院釋字第352、575、589、605號解釋）、或與此五種型態類似（例如司法院釋字第472、538、547、580、714號解釋），為避免重複，則不再贅述。

一、司法院釋字第410號解釋

舊民法親屬編有關「聯合財產制」之立法設計，係遷就民初當時之家庭角色分配——即女性多無外出營生之經濟能力；另一方面為保護夫之債權人，避免夫脫產於妻而生詐害債權等情事發生。因此規定夫享有聯合財產之管理使用權、妻原有財產之孳息收取權、以及聯合財產中扣除妻原有財產後剩餘部分之所有權（1985年修正前民法第1017條參照）。在此規定之下，妻於婚姻關係存續中始行取得之不動產，即便以妻之名義登記，其所有權仍歸之於夫。惟鑑於婚姻生活的圓滿和諧，須有賴夫妻雙方之共同協力，聯合財產制下之財產歸屬，並未對已婚女性生兒育女、操持家務之貢獻給予足夠的評價；且聯合財產制下對女性的角色預設，已隨著女性逐漸走出家庭進入職場就業而產生脫節；加上登記於妻之不動產所有權卻歸屬於夫，亦與土地法第43條揭示之登記公示制度有所違背¹³⁵。有鑑於此，立法者於1985年修正民法第1017條，使夫妻原有財產之範圍，得以趨於一致。惟該法律修正並未設有溯及之特別規定，致修正前已發生現尚存在之聯合財產，仍由夫繼續享有權利，而未能貫徹憲法保障男女平等之意旨。

在此，系爭規定所涉及者為已婚女性（妻）之「財產權」，應無疑義。惟本號解釋特殊之處，在於聲請意旨非以法律有溯及既往為由，反而係以法律應溯及未溯及而加以指摘¹³⁶。由於舊制中除特有或原有財產外，妻之財產皆納入聯合財產之範疇，而盡歸於夫所

135 司法院釋字第410號解釋聲請書參照。

136 彭鳳至（註90），頁8。

有，是以妻要求有利新法之溯及，對夫而言勢必構成「不利之溯及」。在此基本權衝突下權利相互間之此消彼長，國家除對已婚女性負有「保護不足禁止」(Untermaßverbot)之義務外，亦應斟酌既已存在之法律秩序，避免對夫造成過度之侵害。換言之，立法者對聯合財產制下夫妻間各自財產之形塑、調整與界定，其指導原則除了促進兩性地位之實質平等外(憲法增修條文第10條第6項)，還是離不開「憲法基本權保障」。這也是之後立法機關不依聲請人主張——逕對妻作有利新法之溯及，而是在民法親屬編施行法中另設第6條之1，賦予夫妻雙方於一年緩衝期間內重新認定財產權歸屬之理由所在¹³⁷。

二、司法院釋字第525號解釋

銓敘部發布四年制志願役預備軍官得比照常備軍官軍職年資比敘相當俸給之函釋(1987年)，因其有違「後備軍人轉任公職考試比敘條例」規定之意旨，而遭銓敘部以新函釋予以停止適用(1995年)，此致因舊函釋入伍服役並依法退伍之聲請人，於其考試及格(1997年)並取得公務人員任用資格時(1998年)，其銓敘送審軍中年資無從再依比敘方式辦理，而主張新函釋有違憲法第7條之平等原則。

本號解釋理由書認為，任何法規皆非永久不能改變，法規未來可能修改或廢止，受規範之對象並非毫無預見。因而舊函釋停止適用時，尚未考試及格亦未取得公務人員任用資格者，難謂法規廢止時已有客觀上信賴事實之具體表現，此際僅為法規適用對象之主觀願望或期待，自不得主張因該比敘措施廢止而受有信賴利益之損失。相異於此，劉鐵錚大法官於該號不同意見書中指出，聲請人應召入伍時，因信賴該函令而志願轉服四年制預備軍官役並依法退伍

¹³⁷ 立法院公報，85卷40期，頁247-254(1996年)。

者，此即信賴事實之具體表現；而日後取得公務人員任用資格時得主張比敘優惠之適用，此乃信賴利益之所在；至於舊函釋規定之比敘優惠期間將於何時停止適用，則根本不能產生預見。是以皆為同一信賴基礎，國家竟以不同標準待之，其不僅違反實質平等，亦罔顧人民對舊函釋所生之合理信賴¹³⁸。

實則，將後備軍人轉任公職考試比敘條例第3條第1款之適用對象，擴張及於志願服四年預備軍官現役退伍後備軍人之舊函釋，其性質係不對外發生法效力之「解釋性行政規則」，是以長久以來銓敘送審軍中年資得比敘相當俸給，毋寧只是函釋之適用結果，並非本案聲請人之權利，從而主管機關對舊函釋之停止適用，並未構成人民權利之侵害。至於因此產生之差別對待，則應以「平等原則」加以審查。

本號解釋多數意見認為：「舊函釋之停止適用未有過渡期間之設，固有可議之處，惟為維護憲法所揭示公開競爭考試制度及法律所定正常文官甄補管道，其利益顯然優於對少數延長役預備軍官賦予之特殊優待。」本文認為此段文字雖足以證立國家在此合理差別待遇的形成，惟解釋文中倘能另就聲請人於過程所投注之努力（選擇役期較長之四年志願役）、以及給予相同待遇是否會造成整體新制達成之妨礙或國家財政重大負擔等因素一併加以著墨，勢將能為本號解釋帶來更多的論理支持。

三、司法院釋字第529號解釋

過去金馬地區因實施戰地政務，依當時「動員時期民防辦法」規定，該地區十六歲之男子，應編入民防自衛隊服勤並接受軍事訓練，並得於其年滿十八歲時，依「金馬地區役齡男子檢定為已訓乙種國民兵實施辦法」（以下簡稱：檢定已訓辦法），申請檢定為已訓

138 司法院釋字第525號劉鐵錚大法官不同意見書參照。

乙種國民兵。聲請人於服勤並實受軍事訓練完畢之後，因逢動員戡亂時期終止而結束金馬地區戰地政務，上開檢定已訓辦法亦一併廢止，致未及申請檢定之聲請人，其日後得免服常備兵役之法律地位為之喪失，而聲請司法院解釋。

動員戡亂期間所頒布之「檢定已訓辦法」，係來自當時兵役法施行法第24條之授權，且其規定金馬地區男子符合相關要件者，得檢定為已訓乙種國民兵，此顯然涉及人民服兵役義務之役別、訓練期間與勤務種類，自應理解為具法效性之外部法規。

本號解釋之關鍵，在於申請檢定已訓之前，人民是否有「權利」已為成形。多數意見認為，聲請人得於其他要件具備時依法請求檢定為已訓乙種國民兵，即為應受保護之實體法上地位。許宗力大法官亦主張，本號事實中聲請人取得已訓乙種國民兵之資格要件已近乎完備，唯一尚未符合之要件（年滿十八歲），其實現在客觀上亦可合理期待，由於權利取得之接近，此階段聲請人之利益，應強化到具「期待權」之性質¹³⁹。對此本文認為，憲法第20條：「人民有依法律服兵役之義務。」其已揭示人民兵役義務之內容，必須仰賴「法律」（含法律授權之命令）之明文加以判定。依檢定已訓辦法，須年滿十八歲之金馬地區役齡男子始得申請檢定為已訓乙種國民兵，故欠缺此該法定要件之本案聲請人，顯然未取得系爭權利。從而主管機關嗣後對檢定已訓辦法之廢止，並未構成公權利之侵害，自與憲法基本權之防禦功能無涉。

不過檢定已訓辦法的廢止，雖為國家回歸常態法制所必要，惟其所造成者，係同樣被編入民防隊服勤並實受軍事訓練完畢，卻僅因未滿十八歲致無從申請檢定為已訓乙種國民兵之不合理差別對待，而有違兵役制度之公平性。基於「平等原則」之考量，本文認為主管機關應比照系爭辦法廢止前之處理，給予本案聲請人等同之

139 司法院釋字第574號許宗力大法官協同意見書第二點參照。

待遇。

四、司法院釋字第574號解釋

本號解釋係起因於聲請人之案件，歷經第三審法院二次廢棄後發回第二審法院更為審判，期間因民事訴訟法第466條修正提高財產權訴訟第三審上訴利益之數額，致聲請人最後因不符新法之規定而不得上訴第三審。

首先應予釐清者係，本案當事人不得上訴第三審，究為當事人訴訟權之欠缺，抑或是立法者對人民訴訟權行使之限制。多數意見顯然採取了前者之立場，其認為必須等到第二審判決之作成，始能斷定當事人有無具備第三審之上訴利益；亦即倘第二審訴訟程序尚在進行中，當事人即不具有上訴第三審之訴訟權。然而應予思考者是：「第二審判決之作成」倘為當事人取得上訴第三審之要件前提，則對案件仍在進行中且尚未作成第二審判決之釋憲聲請人，其顯然未取得上訴第三審之程序利益，立法者就民事訴訟法第466條之修正，自無「公權利受侵害」之問題；在此大法官不僅毋庸論證比例原則，甚至應否受理本號解釋之聲請，皆可置疑。不同於前，考量藉由救濟管道的提供以擔保權利實現之訴訟權，其係作為個別權利之功能配備（工具性權利）¹⁴⁰，因此本文認為實體權利（例如財產權）取得之際，即為訴訟權的開始存在之時，兩者時點等同視之，如此方符法諺：「有權利，有救濟（訴訟權）」的理念精神¹⁴¹。而鑑於立法者對我國民事訴訟審級制度之形成，係以「三級三審制」為建置原則，是以權利主體之訴訟權內涵，即為三次審級救濟之機會，任何阻礙上訴至第三審之規定，皆構成對人民訴訟權行使之限制。在此理解下，民事訴訟法第466條關於財產權訴訟第三審

¹⁴⁰ 法治斌、董保城，憲法新論，4版，頁278-279（2010年）。

¹⁴¹ 換言之，憲法第16條之訴訟權並非自「權利受侵犯時」或「進入法院使用時」，始為取得。

上訴利益須逾法定數額之要件規定，並非旨在創設得上訴第三審之程序利益，反而是為當事人訴訟權之行使設下限制。

立法者修正民事訴訟法第466條第三審上訴利益之數額，此涉及較舊法為不利之變更，且其所規範者未涉及已終結之法律關係，故此不利新法應非溯及性新法。而就比例原則之審查，本號解釋認為民事訴訟法第466條之修正：「係立法者衡酌第三審救濟制度之功能及訴訟事件之屬性，避免虛耗國家有限之司法資源，促使私法關係早日確定，以維持社會秩序所為之正當合理之限制，與憲法第16、23條尚無違背。」再者，因訴訟權之目的旨在救濟權利（取得有利判決），而非上訴至第三審級¹⁴²，因而提高上訴第三審門檻之系爭新法，並未構成人民訴訟權之過度侵犯。至於本號聲請事實中，因案件一再發回更審致依新法不得再上訴第三審，此等法院判決之違失雖不可歸責於當事人，惟考量發回更審實已增加國家司法資源之耗費，故此特殊情形縱未為立法者修法時所斟酌，本文認為此與憲法第16條訴訟權之保障，應無牴觸。

五、司法院釋字第577號解釋

1997年菸害防制法通過並公布後，其第8條第1項課予菸品業者標示尼古丁及焦油含量於菸品容器上之義務，違反者得依同法第21條處以罰鍰，並於該法第30條第1項設有「本法自公布後六個月施行」之過渡期間條款規定。聲請人爭執此不利新法之規定雖看似完備，惟針對尼古丁及焦油含量之標示方式（字體顏色、大小、位置），主管機關卻遲至新法「施行後」四十日始為拍板定案，並且於聲請人斥資進行菸品回收及標示黏貼工作之際，某地方政府衛生局仍以特定超市販售聲請人進口之菸品未加標示為由，而對聲請人予以開罰¹⁴³。

¹⁴² 司法院釋字第574號許宗力大法官協同意見書第二點。

¹⁴³ 司法院釋字第577號釋憲聲請書參照。

菸害防制法之訂定，並非針對已為終結之法律關係加以規範，而係就人民於新法公布後所生產、經銷或販售菸品增加過去所無之標示義務，在定位上非屬溯及性新法。而就比例原則之審查，大法官認為：「系爭規定雖對於菸品業者之不表意自由有所限制，然其目的係為維護國民健康及提供消費者必要商業資訊等重大之公共利益，其手段與目的間之實質關聯，符合法治國家比例原則之要求，並未逾越維護公共利益所必要之程度，而與憲法第11、23條之規定均無違背。」值得注意者係，規定菸品容器應作一定之標示，此義務雖未構成菸品業者權利之過度侵犯，屬於企業應盡之社會責任範疇，惟鑑於標示義務之履行須耗費相當時日，加上義務違反如被查獲將面臨行政罰之制裁，因而該法第30條第1項另設有為期六個月之過渡期間條款，使菸品業者得就新法的上路預作準備，不致於因此而蒙受重大損失。

本文認為，聲請人對於菸害防制法第8條第1項有關標示義務的理解，似乎顯得過於拘謹與保守。主因在於系爭新法僅對於菸品業者之「標示義務」加以規定，並未就標示之「方式」有所著墨。換言之，只要聲請人依法據實標示尼古丁及焦油含量於菸品容器上，縱該標示不符後來主管機關函告之方式，至多僅為方式改正而已，無論如何聲請人都不會該當系爭新法第21條之處罰要件。這也正是本號多數意見認為，系爭規定之菸品標示義務與責任，「舉凡規範對象、行為及法律效果皆屬明確」，難謂有聲請人指稱——違反法治國家法律明確性原則之情形存在。

陸、立法建議

旨在處理法秩序不利變更之信賴保護原則，因其涉及國家高權對人民公權利之侵犯，除了須無違法律保留原則與比例原則外，亦

應依情形給予受害人民相當之損失填補，方符憲法基本權保障之理念意旨。承此以言，筆者建議現行法制宜作適度之增刪，期以合乎信賴保護原則本身之制度原理（以下一、），並作為落實信賴保護原則之完整配套（以下二、三、）。

一、刪除知悉處分違法即排除保護之規定

「授益處分」係行政機關本於上下權力服從關係所為之單方規制，在法律狀態上產生授予利益法效果，並成為處分相對人獲享公權利之客觀證明。授益處分之違法，倘因相對人惡意取得權利而造成，仍須視其違法情節予以減免保護，此開說明已見前述¹⁴⁴；反之，處分違法如源於行政機關本身認事用法之違誤，其非難對象應為作成處分之國家機關，而非單純知悉處分違法之相對人，行政程序法第119條第3款就處分相對人的保護排除，顯然未作合宜的歸責分配¹⁴⁵。鑑於在法治國家中，信賴保護即意謂著憲法基本權保障，因而本文建議將行政程序法第119條之條目說明由「信賴不值得保護」改為「授益處分相對人公權利之減免保護」，並將該條第3款（含訴願法第80條第2項第3款）：「明知行政處分違法或因重大過失而不知者」之規定予以刪除，期以兼顧個案實際情形與處分相對人之權益保護。

二、刪除行政機關撤銷授益處分之期限規定

我國行政程序法第121條第1項：「第一百十七條之撤銷權，應自原處分機關或其上級機關知有撤銷原因時起二年內為之。」此就行政機關授益處分撤銷權限之行使設下時間限制，其寓有促成法秩序安定之意旨¹⁴⁶。然而在個案操作上，如何認定「機關組織體」之

144 請見本文段落：「參、三、（一）（二）」之說明。

145 請見本文段落：「參、三、（三）」所舉之事例。

146 此即意謂：在二年除斥期間經過前，法秩序尚處於不安定之狀態；如以「法安定性原則」推之，因法秩序不安定無從對之投以信賴，將導致此段期間不

主觀知悉，學說見解極為分歧，並且二年期間經過後倘一律不許撤銷，恐使行政機關面臨公益遭受重大危害卻束手無策之困境。例如D申請在飛航管制區興建高樓層建築，承辦公務員明知違法卻仍作成建築許可，俟二年經過後D興建完竣，倘該建物高度足以影響機場航空器之起降，基於飛航安全的考量，自宜准許行政機關撤銷原處分而對該建物加以拆除之。本文認為，因違法授益處分具有回復合法狀態之特殊需求，從而宜賦予行政機關因應此公益之彈性空間，而對撤銷權行使期間予以鬆綁。不過行政機關對授益處分撤銷權的行使，同樣應接受公權利受干預審查流程的檢驗，並依情形給予處分相對人適當之損失填補，乃屬當然之理。

三、增訂行政機關之對內求償權

行政機關撤銷違法授益處分，依法自應填補人民因此所受之實際損失，已如前述。惟國家損失填補責任之承擔，倘肇因個別公務員違法授益處分的作成，且其主觀上具有故意或重大過失，自不應免於責任之外，以符事理之平。從而在立法設計上，宜仿照國家賠償法第2條第3項之立法例，肯認補償機關對公務員之內部求償權。承此，本文建議在行政程序法第120條中，另增設「違法授益處分之作成，公務員有故意或重大過失時，行政機關對之有求償權。」等文字，用以督促機關公務員謹慎行事、從公執法。

柒、結語

總結前開論述的檢視，我們可以得知信賴保護原則之課題，並非指向：內心主觀信賴之保護、信賴利益之保護、或者信賴損失之保護，而是回歸到公法學的傳統脈絡——憲法基本權保障。既然法

生信賴保護，而與「授益處分之撤銷涉及信賴保護原則」之命題產生扞格。

秩序變遷下之信賴保護原則，其旨在處理人民之「公權利」保護而非「信賴」保護，並且改以基本權受干預審查模式反而更能貼近憲法之規範意旨，則為避免概念之混淆與減輕思維的負擔，在法治國家中之立法、行政領域，信賴保護原則一詞及其三要件審查體系（信賴基礎／信賴表現／信賴值得保護），本文認為或許可以考慮捨棄、刪除。

至於國家錯誤決定的作成（例如誤發錄取通知）並即刻更正、提出無法實現的承諾或保證、以及行政規則的朝令夕改，此等高權舉措除了造成人民內心期待的落空，亦導致國家本身威信的減損喪失。針對人民對國家的信任關係，雖然不能透過法律制度尋求救濟，惟其可藉由政治手段（例如選舉）加以解決¹⁴⁷。在此理解下，國家施政應顧及人民之內心主觀信賴，就不會是法治國家原則，而是為落實民意、體現主權在民之「民主國原則」。因而，吾人或可謂：「法治國首重人民權利之保護，民主國首重人民信賴之保護。」

雖然本文對信賴保護原則作了有別以往的理解與詮釋，不過從上個世紀中葉開始，學界在違法受益處分撤銷之案例中開展出信賴保護之理念，使國家在追求公益、回復合法狀態的同時，必須一併兼顧人民之既得權利保障，用以促成公益與私益間之調和，並且其「應採行補救措施或訂定過渡期間條款」之規範論述，亦補充現有基本權（自由權）受干預審查體系之不足，使「憲法基本權保障」的實現更形完備；如果我們可以知曉學者們為此的盡心與努力，那麼走過這半世紀，是有意義的。

¹⁴⁷ 例如立法委員的產生係源於選民之「付託」、總統行使職權必須「無負國民付託」（憲法第48條）、行政內閣的正當性來自於國會之「信任」（憲法增修條文第3條第2項第3款）。

參考文獻

1. 中文部分

- 吳坤城（1997），公法上信賴保護原則初探，收於：城仲模編，行政法之一般法律原則（二），頁235-268，臺北：三民。
- 吳庚（2012），行政法之理論與實用，12版，臺北：自版。
- 李建良（1986），從公法學之觀點論公益之概念與原則，國立中興大學法律研究所碩士論文。
- （1999），行政法上損失補償制度之基本體系，東吳法律學報，11卷2期，頁33-101。
- （2000），論行政處分之違法判斷基準時，收於：臺灣行政法學會編，行政法爭議問題研究（下），頁907-934，臺北：五南。
- （2001），法律的溯及既往與信賴保護原則，台灣本土法學雜誌，24期，頁79-88。
- （2003），基本權利理論體系之構成及其思考層次，收於：憲法理論與實踐（一），2版，頁51-100，臺北：學林。
- （2004），從憲法觀點論軍公教優惠存款的存廢問題，收於：憲法理論與實踐（三），頁437-469，臺北：新學林。
- 李庭熙（1990），論附第三人效力之行政處分，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 李震山（2005），行政損失補償請求權——以行政程序法之補償規定為例，收於：多元、寬容與人權保障——以憲法未列舉權之保障為中心，頁307-373，臺北：元照。
- 林三欽（2008），行政法令變遷與信賴保護——論行政機關處理新舊法秩序交替問題之原則，收於：「行政爭訟制度」與「信賴保護原則」之課題，頁291-355，臺北：新學林。

- (2008), 論授益行政處分之撤銷——思考層次與考量因素的探索, 收於:「行政爭訟制度」與「信賴保護原則」之課題, 頁357-394, 臺北:新學林。
- (2011), 違法授益行政處分受益人之信賴保護——以金錢或可分物給付之授益行政處分為中心, 中研院法學期刊, 9期, 頁1-49。
- 林合民(1985), 公法上之信賴保護原則, 國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 林明昕(2006), 「公法上不當得利」之體系性思考, 收於:公法學的開拓線——理論、實務與體系之建構, 頁231-252, 臺北:自版。
- 林明鏘(2003), 行政規則變動與信賴保護原則——兼評最高行政法院八十九年判字第一八四二號判決與大法官釋字第五二五號解釋, 收於:林明鏘、葛克昌編, 行政法實務與理論(一), 頁577-600, 臺北:元照。
- (2006), 行政契約, 收於:翁岳生編, 行政法(上), 3版, 頁559-597, 臺北:元照。
- 林昱梅(2007), 地價稅之回溯補徵與信賴保護原則, 月旦法學教室, 53期, 頁26-27。
- (2012), 論溯及性法規之合法性問題——從土石採取法「環境維護費收費基準」之時間效力談起, 東吳法律學報, 23卷4期, 頁1-42。
- 林錫堯(2006), 行政法要義, 3版, 臺北:自版。
- 法治斌、董保城(2010), 憲法新論, 4版, 臺北:董保城。
- 洪家殷(1992), 行政處分撤銷之研究, 國立政治大學法律研究所博士論文。
- (2000), 信賴保護及誠信原則, 收於:臺灣行政法學會編, 行政法爭議問題研究(上), 頁117-138, 臺北:五南。
- (2001), 論信賴保護原則之適用——司法院大法官釋字第

- 五二五號解釋評析，台灣本土法學雜誌，27期，頁39-55。
- 孫迺翊（2009），社會給付行政中受益人之信賴利益保護——以德
國社會行政程序法為借鏡，輔仁法學，37期，頁111-183。
- 翁岳生（2009），行政處分之撤銷，收於：法治國家之行政法與司
法，2版，頁31-48，臺北：元照。
- 張文郁（2009），限時法和法律之溯及既往，收於：權利與救濟
（二），頁27-39，臺北：元照。
- 盛子龍（2009），租稅核課處分之不利變更與信賴保護——試評高
雄高等行政法院91年度訴字第891號判決，收於：王必芳編，
2008行政管制與行政爭訟，頁167-215，臺北：中央研究院法
律學研究所籌備處。
- 許宗力（2003），基本權的保障與限制（上），月旦法學教室，11
期，頁64-75。
- （2003），基本權的保障與限制（下），月旦法學教室，14
期，頁50-60。
- （2006），行政處分，收於：翁岳生編，行政法（上），3
版，頁475-558，臺北：元照。
- （2006），基本權利對國庫行為之限制，收於：法與國家權
力（一），頁1-71，臺北：元照。
- 陳春生（2006），事實行為，收於：翁岳生編，行政法（下），3
版，頁1-23，臺北：元照。
- 陳敏（2013），行政法總論，8版，臺北：自版。
- 陳淳文（2007），違法授益行政處分與信賴保護，收於：湯德宗、
李建良編，2006行政管制與行政爭訟，頁1-45，臺北：中央研
究院法律學研究所籌備處。
- 陳清秀（2010），稅法上行政規則之變更與信賴保護，法學新論，
18期，頁53-69。
- 陳慈陽（2007），基本權核心理論之實證化及其難題，2版，臺北：
自版。

- 陳愛娥(2001)，國小校長的「遴用」或「遴選」——法律溯及既往原則的相關問題，台灣本土法學雜誌，21期，頁140-144。
- (2007)，信賴保護原則的具體化——兼評司法院大法官相關解釋，台灣本土法學雜誌，98期，頁159-193。
- 陳新民(2001)，法治國家理念的靈魂——論法律溯及既往的概念、界限與過渡條款的問題，收於：法治國家論，頁147-227，臺北：新學林。
- 陳雍之(1991)，法律之溯及效力——從德國判例及學說論法律變更時人民權益之保護，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 彭鳳至(2003)，法律不溯既往原則之憲法地位，台灣本土法學雜誌，48期，頁3-17。
- 黃俊杰(2001)，解釋函令變更與信賴保護——行政法院八十八年度判字第三九〇七號判決評釋，台灣本土法學雜誌，20期，頁1-13。
- 黃舒芃(2004)，法律保留原則在德國法秩序下的意涵與特徵，中原財經法學，13期，頁1-39。
- 葉百修(2011)，損失補償法，臺北：自版。
- 董保城(2000)，行政處分之撤銷與廢止，收於：臺灣行政法學會編，行政法爭議問題研究(上)，頁473-493，臺北：五南。
- (2006)，行政計畫，收於：翁岳生編，行政法(上)，3版，頁599-616，臺北：元照。
- 蔡宗珍(2008)，撤銷違法行政處分之限制——信賴保護之主張及其效力，月旦法學教室，63期，頁85-89。
- (2011)，退休公教人員優惠存款措施之法律關係及相關信賴保護爭議析論，臺大法學論叢，40卷1期，頁99-138。
- 蕭文生(2000)，基本權利侵害之救濟，收於：李建良·簡資修編，憲法解釋之理論與實務(二)，頁471-496，臺北：中央研究院中山人文社會科學研究所。
- (2010)，授益行政處分之廢止，台灣法學雜誌，151期，頁

105-109。

2. 外文部分

Arnauld, Andreas von (2006), *Rechtssicherheit*, Tübingen: Mohr Siebeck.

Brüning, Christoph (1998), Die Rückwirkung von Legislativakten, *NJW*, S. 1525-1528.

Ehlers, Dirk (2010), Rechtsquellen und Rechtsnormen der Verwaltung, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 14. Aufl., Berlin: De Gruyter, S. 64-134.

Erichsen, Hans-Uwe (1981), Die Aufhebung von Verwaltungsakten durch die Verwaltung, *Jura*, S. 534-546.

Grabitz, Eberhard (1973), Vertrauensschutz als Freiheitsschutz, *DVBl.*, S. 675-684.

Jarass, Hans D./Pieroth, Bodo (2009), *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Kommentar*, 10. Aufl., München: C. H. Beck.

Kisker, Gunter (1974), Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, *VVDStRL* 32, S. 149-193.

Kopp, Ferdinand O./Ramsauer, Ulrich (2011), *Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar*, 12. Aufl., München: C. H. Beck.

Maurer, Hartmut (2006), Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), *Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Bd. IV, 3. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller, S. 395-474.

——— (2007), *Staatsrecht I*, 5. Aufl., München: C. H. Beck.

——— (2009), *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 17. Aufl., München: C. H. Beck.

- Meyer, Hubert (2004), Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes, in: Knack (Hrsg.), *Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar*, 8. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München: Carl Heymanns, S. 949-998.
- Möller, Johannes/Rührmair, Alfred (1999), Die Bedeutung der Grundrechte für die verfassungsrechtlichen Anforderungen an rückwirkende Gesetze, *NJW*, S. 908-911.
- Ossenbühl, Fritz (1972), Vertrauensschutz im sozialen Rechtsstaat, *DÖV*, S. 25-36.
- (1998), *Staatshaftungsrecht*, 5. Aufl., München: C. H. Beck.
- Pieroth, Bodo (1990), Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundsatz des Vertrauensschutzes, *JZ*, S. 279-286.
- Pieroth, Bodo/Schlink, Bernhard (2008), *Staatsrecht II: Grundrechte*, 24. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.
- Püttner, Günter (1974), Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, *VVDStRL* 32, S. 200-225.
- Remmert, Barbara (2010), Verwaltungsrechtsverhältnis, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 14. Aufl., Berlin: De Gruyter, S. 596-613.
- Ruffert, Matthias (2010), Rücknahme von Verwaltungsakten, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 14. Aufl., Berlin: De Gruyter, S. 719-736.
- (2010), Widerruf von Verwaltungsakten, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 14. Aufl., Berlin: De Gruyter, S. 736-742.
- Schenke, Wolf-Rüdiger (1983), Probleme der Bestandskraft von Verwaltungsakten, *DÖV*, S. 320-332.
- Schmidt, Walter (1973), „Vertrauensschutz“ im öffentlichen Recht:

Randpositionen des Eigentums im spätbürgerlichen Rechtsstaat,
JuS, S. 529-537.

Stelkens, Paul/Bonk, Heinz Joachim/Sachs, Michael (2008),
Verwaltungsverfahrensgesetz: Kommentar, 7. Aufl., München: C. H.
Beck.

Ule, Carl Hermann/Laubinger, Hans-Werner (1995),
Verwaltungsverfahrenrecht, 4. Aufl., Köln/Berlin/Bonn/München:
Carl Heymanns.

Vogel, Klaus (1988), Rechtssicherheit und Rückwirkung zwischen
Vernunftrecht und Verfassungsrecht, JZ, S. 833-839.

Wolff, Hans J./Bachof, Otto/Stober, Rolf/Kluth, Winfried (2007),
Verwaltungsrecht I, 12. Aufl., München: C. H. Beck.

Toward a New Theory of Legitimate Expectation

*Chi-Wei Lin**

Abstract

This article reexamines the doctrinal basis for the principle of legitimate expectation. Contrary to the conventional understanding of the principle, this article argues that the principle is derived neither from the principle of good faith nor from the principle of legal stability, but is built on the protection of fundamental rights. Accordingly, the principle of legitimate expectation is of constitutional status and is binding to governmental authorities—including the legislative and the executive branches. Furthermore, this constitutional principle is designed to protect the fundamental rights of the people rather than their sense of reliance. It requires that remedial measures or transitional periods be provided whenever changes in legal order may lead to serious curtailment of human rights. Under this proposed theoretical reconstruction, there is no need to examine such issues as “the foundation of reliance,” “the manifestation of reliance,” and “the protection worthiness of the said reliance.” Instead, the application of this principle should be governed by the framework of the fundamental rights (liberty rights).

KEYWORDS: the principle of good faith, the principle of legal stability, protection of fundamental rights, the principle of no *ex post facto* law, administrative compensation, *Übergangsregelung*, *Sonderopfer*, the theory of the core of fundamental rights, human dignity, death penalty.

* Master of Law, Department of Law, College of Law, Soochow University.